

제17장

소의 객관적 병합

제1절 총 설 110

제2절 소의 객관적 병합의 요건 111

제3절 소의 객관적 병합의 모습 112

제4절 병합소송의 심판 120

제1절 총 설

1. 소의 병합의 여러 형태

소는 소제기의 태양에 따라 ‘단일의 소’와 ‘병합의 소’로 나누어 볼 수 있다.

먼저, ‘단일의 소’란 1인의 원고가 1인의 피고를 상대방으로 하여 1개의 청구를 하는 가장 단순한 소의 형태이다. 이에 비하여 ‘병합의 소’란 단일의 소가 물적 또는 인적으로 여러 개 결합된 것으로서, 1인의 원고가 1인의 피고를 상대방으로 하여 여러 개의 청구를 하는 경우(소의 객관적 병합)와 수인의 원고가 또는 수인의 피고를 상대방으로 소를 제기하는 경우(소의 주관적 병합)가 있다. 병합의 소는 병합요건(민소 65조, 253조)을 갖추어야 한다.

‘병합의 소’, 즉 청구의 병합은 그 병합 시기에 따라 원시적 병합과 후발적 병합으로 나누어 볼 수 있다. 원시적 병합은 원고가 피고에 대하여 소제기 당시부터 하나의 소송절차에 묶어서 여러 개의 청구를 제기하는 경우를 말하고, 후발적 병합은 이미 계속 중인 소송에 새로운 청구를 추가하는 경우(청구의 추가적 변경, 중간확인의 소, 반소, 독립당사자참가)와 법원이 둘 이상 사건의 변론을 병합하는 경우를 말한다.

이중에서 소의 주관적 병합, 즉 공동소송과 소송참가는 앞의 제10장, 제11장에서 이미 설명하였고, 후발적인 소의 객관적 병합(소송중의 소)에 대하여는 다음 제18장에서 살펴보기로 하며, 여기서는 원시적인 소의 객관적 병합에 대하여만 살펴보기로 한다.

2. 소의 객관적 병합(원시적 병합)

‘소의 객관적 병합’이란 원고가 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 하는 경우를 말하는데, ‘소송물의 복수’라고도 하며, 3인 이상의 당사자가 개입하는 소의 주관적 병합인 공동소송에 대응하는 것이다(민소 253조).

소의 객관적 병합은 하나의 소송절차에 청구가 복수인 경우이므로, 하나의 청구를 뒷받침하는 공격방법의 복수와 구별된다. 그런데 청구가 몇 개냐 하는 문제는 소송물이론 중 구소송물이론을 따르느냐, 신소송물이론을 따르느냐에 따라 달라진다. 판례는 구소송물이론에 따라 청구취지와 함께 주로 청구원인을 기준으로 청구의 병합이 있는지를 판가름한다.

제2절 소의 객관적 병합의 요건

1. 같은 종류의 소송절차에 따라 심판될 수 있을 것

병합된 여러 개의 청구가 같은 종류의 소송절차에 따라 심판될 수 있어야 하므로, 서로 다른 소송절차에 따라 심판될 청구는 병합하지 못하는 것이 원칙이다(민소 253조). 통상의 민사소송, 비송사건, 가사소송, 행정소송, 조정사건, 가압류·가처분사건 등의 절차는 서로 다른 절차이기 때문에, 이들 사이에는 병합을 인정하지 않는 것이 원칙이다. 판례도 통상의 민사사건과 가처분에 대한 이의사건은 병합할 수 없다고 한다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2001다23225 판결). 그러나 가사소송과 행정소송에서는 특별규정을 두어 예외적으로 이를 허용하고 있으므로(행소 10조, 가소 14조), 행정소송에서 민사상의 관련 손해배상·부당이득반환 청구를 병합할 수 있고, 가사소송인 이혼소송과 이혼을 원인으로 한 손해배상 청구(가소 2조 1항 1호 다목) 및 가사비송인 재산분할청구를 병합할 수 있다.

재심의 소에 일반 민사상 청구를 병합할 수 있는가에 관하여, 판례는 이를 부정하여 병합한 일반 민사상 청구를 각하하여야 한다고 한다(대법원 1997. 5. 28. 선고 96다41649 판결). 한편 제권판결에 대한 불복의 소(민소 490조 2항)에는 일반 민사상 청구(불법행위 손해배상)를 병합할 수 있지만(대법원 1989. 6. 13. 선고 88다카7962 판결), 형성의 소인 제권판결 불복의 소는

그 판결이 확정됨으로써 비로소 권리변동의 효력이 발생하게 되므로 이에 의하여 형성되는 법률관계를 전제로 하는 이행소송 등은 병합하여 제기할 수 없는 것이 원칙이다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012다36661 판결).

2. 각 청구에 관하여 수소법원에 공통의 관할권이 있을 것

병합사건 중 한 개의 청구에 대하여 관할권을 가지는 법원이 병합된 다른 청구에 관해서도 관련재판적에 의하여 관할권을 가지게 될 때에는(민소 25조), 이 요건은 문제 되지 않는다. 그러나 다른 법원에 전속관할이 있는 사건은 병합하지 못한다.

3. 각 청구 사이의 관련성의 필요 여부

일반적으로 병합사건 상호 간에 아무런 관련성이 없어도 병합심리 대상이 될 수 있는 것이 원칙이다. 그러나 선택적 병합과 예비적 병합에서는 청구의 기초가 되는 사실에 관련성(양립가능성 여부)이 있음을 요하고, 또한 행정소송에서 민사청구를 병합할 경우에는 관련 청구임을 요한다.

제3절 소의 객관적 병합의 모습

1. 단순병합

가. 단순병합의 의의

‘단순병합’이란 원고가 양립하는 여러 개의 청구를 병렬적으로 병합하여 그 전부에 관하여 판결을 구하는 형태를 말한다. 병합된 다른 청구의 당부와 관계없이 각 청구 모두에 관하여 심판을 구하는 것이기 때문에 병합된 모든 청구에 대하여 법원의 심판이 필요하다. 예컨대 ① 소유물반환 청구와 손해배상 청구, ② 매매대금 청구와 대여금 청구, ③ 불법행위로 인한 손해배상

사건에서의 치료비 등 청구, 일실회의 청구, 위자료 청구 등이다(손해3분설).

단순병합은 각 청구 간에 법률상·사실상 아무런 관련이 없는 경우가 대부분이지만, 병합된 여러 개의 청구 간에 논리적으로 서로 관련되어 있는 경우도 있다. 예컨대 매매계약무효확인 청구와 함께 그 매매가 무효라고 인정될 경우에 매매로 넘어간 목적물의 반환도 병합하여 청구하는 경우 또는 사해행위인 계약의 취소를 청구하면서 아울러 그 계약을 원인으로 마쳐졌던 등기의 말소등기절차이행을 병합하여 청구하는 경우에는, 모두 후자는 전자에 종속되는 관련성이 있기는 하지만 원고로서는 두 개의 승소판결을 구하는 것이므로 어디까지나 단순병합일 뿐 예비적 병합이 아니다. 즉 제1차적 청구가 인용될 것을 전제로 하여 제2차적 청구에 대하여도 심판을 구하는 경우로서, 제1차적 청구가 인용될 때에는 두 청구 모두 판단하여 별도로 두 개의 주문을 내야 하며, 제1차적 청구가 배척될 때에는 제2차적 청구에 대하여는 더 이상 판단할 필요 없이 둘 다 기각하면 된다.

논리적으로 전혀 관계가 없어 순수하게 단순병합으로 구하여야 할 수 개의 청구를 선택적 또는 예비적 청구로 병합하여 청구하는 것은 부적법하여 허용되지 않는다. 따라서 원고가 그와 같은 형태로 소를 제기한 경우 법원은 소송지휘권을 적절히 행사하여 이를 단순병합 청구로 보정하게 하는 등의 조치를 취하여야 하고, 법원이 이러한 조치를 취함이 없이 본안판결을 하면서 그중 하나의 청구에 대하여만 심리·판단하여 이를 인용하고 나머지 청구에 대한 심리·판단을 모두 생략하는 내용의 판결을 하였다 하더라도 그로 인하여 청구의 병합 형태가 선택적 또는 예비적 병합 관계로 바뀔 수는 없으므로, 이러한 판결에 대하여 피고만이 항소한 경우 제1심법원이 심리·판단하여 인용한 청구만이 항소심으로 이심될 뿐, 나머지 심리·판단하지 않은 청구는 여전히 제1심에 남아 있게 된다(대법원 2008. 12. 11. 선고 2005다 51495 판결).

나. 대상청구의 병합 형태

물건의 인도청구와 함께 그것을 갈음하는 금전지급을 청구하는 대상청구에는 두 가지 형태가 있다.

첫째로, 원고가 물건(특정물 또는 대체물)의 인도청구와 함께 변론종결 후의 이행불능(특정물의 경우)이나 집행불능(대체물의 경우)이 될 것을 대비하여 대상청구로서 미리 이행판결을 구하는 경우이다. 이 경우에는 현재이행의 소와 장래의 이행불능(특정물) 또는 집행불능(대체물)으로 인한 전보배상을 미리 청구하는 장래이행의 소의 단순병합에 해당한다(대법원 2024. 7. 25. 선고 2021다239905 판결). 따라서 물건인도 청구가 인용되는 경우에는 대상청구에 대하여도 함께 판단하여 별도의 주문을 내야 하지만, 물건인도 청구가 이유 없을 때에는 대상청구에 대하여 심리할 것도 없이 모두 배척하면 된다(대법원 1969. 10. 28. 선고 68다158 판결). 이러한 대상청구를 본래의 급부청구에 예비적으로 병합한 경우에도 본래의 급부청구가 인용된다는 이유만으로 예비적 청구에 대한 판단을 생략하여서는 안 된다(대법원 2011. 8. 18. 선고 2011다30666 판결).

둘째로, 특정물의 인도청구를 하면서 변론종결 전에 피고가 그 물건을 매도하거나 훼손·멸실시켜 이행불능이 되게 하는 것을 염려하여 그 전보배상을 함께 청구하는 경우는 하나의 판결만을 구하는 예비적 병합에 속한다. 따라서 법원으로서서는 먼저 제1차적 청구인 물건인도청구를 심리하여 변론종결 당시 이행이 가능하다고 보아 이를 인용할 경우 제2차적 청구인 전보배상청구에 관하여 판단할 필요가 없으나, 만일 변론종결 전에 이미 이행불능에 이르렀음이 판명되면 제1차적 청구를 기각하고 제2차적 청구에 대하여 심리·판단하여야 한다(대법원 1962. 6. 14. 선고 62다172 판결).

2. 선택적 병합

가. 선택적 병합의 의의와 요건

청구의 선택적 병합은, 양립할 수 있는 여러 개의 청구권으로 동일한 취지의 급부를 구하거나 양립할 수 있는 여러 개의 형성권으로 동일한 형성적 효과를 구하는 경우에, 그 어느 한 청구가 인용될 것을 해제조건으로 하여 여러 개의 청구에 관한 심판을 구하는 병합 형태이다(대법원 2016. 5. 19. 선고 2009다66549 전원합의체 판결).

선택적 병합과 후술하는 예비적 병합은 단순병합과 달리 하나의 소로서 논리적으로 관련성 있는 여러 개의 청구를 불가분적으로 결합한 병합의 형태이다. 선택적 병합과 예비적 병합은 모두 관련성 있는 여러 개의 청구를 하나의 소송에 결합하여 소송경제를 도모하고, 하나의 분쟁에 관한 판결이 서로 저촉되는 것과 같은 불합리를 피하자는 데에 그 목적이 있다. 양 병합은 모두 ① 수 개의 청구 사이에 논리적으로 밀접한 관련성이 있을 것으로 요하고, ② 양립가능성이 있는지(선택적) 없는지(예비적)에 따라 서로 구분된다. 따라서 논리적으로 전혀 관계가 없어(① 요건 불충족) 순수하게 단순병합으로 구하여야 할 수 개의 청구를 선택적 또는 예비적 청구로 병합하여 청구하는 것은 부적법하여 허용되지 않는다(대법원 2008. 12. 11. 선고 2005다51495 판결. 이때 법원은 소송지휘권을 행사하여 단순병합 청구로 보정하도록 조치해야 한다). 나아가 소장 또는 청구취지 및 청구원인 변경신청서의 기재에 따르더라도 원고의 청구가 선택적 병합인지 예비적 병합인지 여부에 관하여 명확하게 표시되지 않는다면 법원은 이를 밝히도록 촉구하는 방법으로 석명권을 행사하여 이를 분명히 한 후 그에 따른 판단을 하여야 한다(대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다299383 판결).

선택적 병합은 양립할 수 있는 여러 개의 실체상의 청구권이나 형성권에 기하여 동일한 청구취지의 이행이나 형성을 구하는 것이 보통이나, 그 청구취지를 달리 할 수도 있다. 전자의 예로는 소유권과 점유권에 터 잡아 동일

한 물건의 인도를 청구하거나 또는 불법행위와 채무불이행을 이유로 같은 금액의 손해배상을 청구하는 경우 등이 있고, 후자의 예로는 명의신탁 해지에 따라 신탁관계의 종료를 이유로 소유권이전등기를 구하는 것과 소유권에 터 잡아 소유권이전등기의 말소를 구하는 것을 들 수 있다.

원고가 동일 피고에 대하여 여러 개의 청구를 하고 있는 경우 그 병합형태가 선택적 병합인지, 예비적 병합인지 불분명한 때에는 법원은 석명권을 행사하여 이를 밝혀야 함이 원칙이나, 원고의 청구를 기각하는 경우에는 어차피 원고의 청구 전부를 판단하여야 하기 때문에 그 점을 밝히지 않아도 위법이라고 할 수 없다(대법원 1962. 6. 21. 선고 62다212 판결). 채무불이행 책임과 불법행위 책임의 관계에 관하여, 판례는 각각 요건과 효과를 달리하는 별개의 법률관계에서 발생하는 것으로서 두 개의 손해배상청구권이 경합하여 발생하므로 선택적 관계에 있다고 한다(대법원 1989. 4. 11. 선고 88다카 11428 판결).

나. 순위를 붙인 선택적 병합(부진정 예비적 병합)

선택적 병합이 가능한 논리적으로 양립할 수 있는 수 개의 청구라고 하더라도, 주위적으로 재산상 손해배상을 청구하면서 그 손해가 인정되지 않을 경우에 예비적으로 같은 액수의 정신적 손해배상을 청구하는 것과 같이 수 개의 청구 사이에 논리적 관계가 밀접하고, 심판의 순위를 붙여 청구를 할 합리적 필요성이 있다고 인정되는 경우에는, 당사자가 붙인 순위에 따라서 당사자가 먼저 구하는 청구를 심리하여 이유가 없으면 다음 청구를 심리하는 이른바 ‘부진정 예비적 병합’ 청구의 소도 허용된다(대법원 2021. 5. 7. 선고 2020다292411 판결).

한편 부진정 예비적 병합 청구의 경우, 주위적 청구가 전부 인용되지 않을 경우에는 주위적 청구에서 인용되지 아니한 수액 범위 내에서의 예비적 청구에 대해서도 판단하여 주기를 바라는 취지로 불가분적으로 결합시켜 제

소할 수도 있는 것이므로, 주위적 청구가 일부만 인용되는 경우에 나아가서 예비적 청구를 심리할 것인지의 여부는 소송에서의 당사자의 의사 해석에 달린 문제라 할 것이어서, 법원이 주위적 청구원인에 기한 청구의 일부를 기각하고 예비적 청구취지보다 적은 금액만을 인용할 경우에는, 원고에게 주위적 청구가 전부 인용되지 않을 경우에는 주위적 청구에서 인용되지 아니한 수액 범위 내에서의 예비적 청구에 대해서도 판단하여 주기를 바라는 취지인지 여부를 석명하여 그 결과에 따라 예비적 청구에 대한 판단 여부를 정하여야 할 것이다(대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다23598 판결).

또한 부진정 예비적 병합의 경우에도 주위적 청구를 먼저 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용하거나 주위적 청구만을 배척하고 예비적 청구에 대하여 판단하지 않는 등의 일부판결은 예비적 병합의 성질에 반하는 것으로서 법률상 허용되지 않는다. 그런데도 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대하여 판단하지 않은 판결을 한 경우에는 그 판결에 대한 상소가 제기 되면 판단이 누락된 예비적 청구 부분도 상소심으로 이심이 되고 그 부분이 재판의 누락에 해당하여 원심에 계속 중이라고 볼 것은 아니다(대법원 2021. 5. 7. 선고 2020다292411 판결).

다만 병합의 형태에 따라 항소심에서의 심판 범위가 달라지는 경우 병합의 형태에 대한 판단은 당사자의 의사가 아닌 병합청구의 성질을 기준으로 하여야 한다(대법원 2018. 2. 28. 선고 2013다26425 판결 참조). 따라서 실질적으로 선택적 병합 관계에 있는 두 청구에 관하여 당사자가 주위적·예비적으로 순위를 붙여 청구하였고, 그에 대하여 제1심법원이 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구만을 인용하는 판결을 선고하여 피고만이 항소를 제기한 경우에도 항소심으로서 그 명칭(주위적·예비적 청구)에도 불구하고 성질상 선택적 병합 청구로 보아 두 청구 모두를 심판의 대상으로 삼아 판단하여야 한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다96868 판결, 대법원 2021. 6. 24. 선고 2016두61877 판결, 대법원 2022. 5. 12. 선고 2020다278873 판결).

3. 예비적 병합

가. 예비적 병합의 의의와 요건

‘예비적 병합’이란 논리적으로 관련되지만 양립할 수 없는 여러 개의 청구를 하면서 주위적 청구(제1차적 청구)가 기각되거나 각하될 경우에 대비하여 예비적 청구(제2차적 청구)에 대하여 심판을 구하는 형태의 병합을 말한다. 즉 주위적 청구가 인용되지 아니할 경우에 한하여 예비적 청구의 심판을 구하는 병합 형태이다. 예비적 병합은 원고가 주위적 청구에 대하여 증거가 어렵다든지 법률적으로 자신이 없는 경우 주위적 청구가 기각된 후에 신소를 제기하는 번잡을 피하고 재판의 모순에 의한 불이익을 방지하자는 것으로, 동일 동종의 법률상 경제적 목적을 추구하는 경우 가능하지만, 달성하려고 하는 소송의 목적, 즉 급부나 형성되는 권리관계가 반드시 동일한 것은 아니다.

예비적 병합이 허용되기 위한 요건으로서는, 첫째 예비적 청구는 주위적 청구와 서로 논리적으로 양립될 수 없는 모순관계에 있어야 하고, 둘째 두 청구의 기초가 되는 사실관계가 서로 관련성이 있어야 한다. 예를 들면 주위적 청구로서 매매계약에 기하여 매도대금의 지급을 청구하고 매매계약이 무효여서 주위적 청구가 기각될 것에 대비하여 예비적 청구로서 부당이득을 이유로 이미 인도한 매매목적물의 반환을 청구하는 경우나, 주위적 청구로서 물건의 인도를 청구하고 변론종결 당시 그 이행이 불가능하게 되었음이 판명될 것에 대비하여 예비적 청구로서 그 물건의 인도를 갈음하는 전보배상을 청구하는 경우(반면 변론종결 이후 집행불능을 대비하는 예비적 청구는 단순병합에 해당한다) 등이다. 이와 같이 예비적 병합은 두 청구가 서로 양립될 수 없는 상호배척관계에 있다는 점과 심판 순서의 정함이 있다는 점에서, 선택적 병합과 차이가 있다.

한편 양립 가능한 두 청구에 대한 ‘순위를 붙인 선택적 병합’이 허용되는 것과는 반대로, 양립되지 않는 관계의 두 청구에 대하여는 예비적 병합만이 가능하고 선택적 병합 또는 단순병합이 허용될 수 없다(대법원 1999. 8. 20.

선고 97누6889 판결).

나아가 병합의 형태는 당사자의 의사가 아닌 병합청구의 성질을 기준으로 판단하여야 하므로, 원고가 성질상 주위적·예비적 관계에 있는 두 청구를 단순병합 형태로 청구하였더라도 법원으로서서는 이를 주위적·예비적 청구로 보아 그 순서에 따라 판단하여야 한다(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017다288689 판결).

나. 두 청구가 흡수관계에 있는 경우

예비적 청구는 위에서 본 바와 같이 주위적 청구와의 사이에 양립되지 아니하는 관계에 있어야 한다. 즉 양자 사이에는 서로 배척되고 모순되는 관계에 있고, 심판순위가 당사자가 청구한 심판의 순서에 따라 후순위여야 한다(대법원 1993. 3. 23. 선고 92다51204 판결).

그런데 청구원인을 같이 하면서 주위적 청구의 수량만을 감축한 예비적 청구는 주위적 청구에 흡수되는 것일 뿐 여기서 말하는 소송상의 예비적 청구라고 할 수 없으므로 이를 별도로 판단할 필요가 없다(대법원 1991. 5. 28. 선고 90누1120 판결, 대법원 2017. 10. 31. 선고 2015다65042 판결). 또한 주위적으로 무조건의 이행청구를 하고 예비적으로 동시이행의 조건 등을 붙여서 이행청구를 하는 경우도 마찬가지로 보아야 할 것이다(대법원 1999. 4. 23. 선고 98다61463 판결). 이러한 경우에는 병합된 청구가 모순되는 관계가 아니라 양적 또는 질적으로 흡수관계에 있기 때문이다.

다만 주위적 청구와 예비적 청구가 분할 가능한 것이고 주위적 청구가 일부만 인용되는 경우에 나아가서 예비적 청구를 심리할 것인지의 여부는 소송에서의 당사자 의사 해석에 달린 문제라고 할 것이므로, ‘주위적 청구의 일부를 특정하여’ 그 부분이 인용될 것을 해제조건으로 하여 그 부분에 대해서만 하는 예비적 청구는 허용될 수 있다. 그러나 위와 같은 특별한 사정이 없다면 주위적 청구 일부가 기각될 것이라 하더라도 다시 그 부분에 대한

예비적 청구에 관하여 나아가 판단할 필요가 없다(대법원 2000. 4. 7. 선고 99다53742 판결).

제4절 병합소송의 심판

1. 병합요건 등의 조사

우선 병합요건은 청구의 병합에 특유한 소송요건이므로, 그 구비 여부에 관하여 법원이 직권으로 조사하여야 한다. 병합요건에 흠이 있는 경우에는 변론을 병합하지 말고 별소로 각각 심판하는 것이 원칙이다. 병합요건이 갖추어졌으면 각 청구에 관하여 소송요건 구비 여부를 직권으로 조사하여 흠이 있으면 그 청구 부분의 소를 부적법 각하한다(민소 219조). 만일, 병합청구 중 어느 하나가 다른 법원의 전속관할에 속하는 때에는 결정으로 이송하여야 할 것이다(34조).

사물관할과 인지액의 표준이 되는 소송목적의 값을 산정할 경우에, 단순 병합에서는 병합된 청구의 가액을 합산하는 것이 원칙이지만(합산주의, 민소 27조 1항), 선택적 병합이나 예비적 병합에서는 1개의 소로 주장하는 경제적 이익이 동일하기 때문에 각 청구의 가액을 합산하지 않고 그중 다액 청구의 가액에 의한다(흡수주의, 인지규 20조 참조).

2. 심리의 공통

조사 결과 병합요건 및 소송요건이 구비되어 있으면 병합된 여러 개의 청구의 변론·증거조사 및 판결은 같은 기일에 여러 개의 청구에 대해서 공통으로 행하며, 여기서 현출된 증거자료나 소송자료는 모든 청구에 대한 공동의 판단자료가 된다.

법원은 변론을 병합한 청구 중 어느 한 청구만으로 일시 제한하거나 또는

어떤 청구에 대하여 변론의 분리를 명할 수 있지만(민소 141조), 변론의 분리는 단순병합의 경우에만 허용된다. 위에서 본 바와 같이 선택적 병합이나 예비적 병합은 여러 개의 청구가 불가분적으로 결합된 것이므로 그 성질상 변론의 분리가 허용되지 않음(대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결)은 물론, 병합된 여러 개의 청구 중 어느 한 청구에 대하여만 중지사유가 생긴 경우에도 변론을 분리하지 않고 청구 전부에 대하여 소송절차를 중지한다.

3. 종국판결

가. 단순병합의 경우

병합된 모든 청구에 대해서 판결하여야 하되, 각 청구가 동시에 판결할 수 있을 정도로 전부 심리되었으면 1개의 전부판결을 하고(민소 198조), 일부만 재판할 정도로 심리되었을 경우에는 그 부분에 대해서만 일부판결을 할 수 있다(200조). 모든 청구에 대하여 판단하여야 하기 때문에 어느 하나의 청구에 대하여 재판을 누락하면 추가판결의 대상이 된다(212조).

단순병합된 여러 청구 중 일부판결이 선고되고 그에 대하여 상소한 때에는 나머지 부분과 별도로 이심의 효력이 생긴다. 반면 병합된 여러 청구에 대하여 하나의 전부판결이 선고되고 그중 일부에 대하여만 상소한 경우에는 모든 청구에 대하여 이심과 확정차단의 효력이 생기나(대법원 1966. 6. 28. 선고 66다711 판결), 다만 항소인이 그 변론 종결 시까지 항소취지를 확장하지 아니하는 한 불복하지 아니한 나머지 부분은 항소심의 심판대상이 되지 아니하므로 그 부분에 관하여는 항소심판결의 선고와 동시에 확정되어 소송이 종료된다(대법원 1994. 12. 23. 선고 94다44644 판결, 대법원 2001. 4. 27. 선고 99다30312 판결). 나아가 위와 같이 항소심 심판대상이 아닌 부분(제1심 판결의 원고 패소 부분)에 관하여 항소심 판결이유에서 그 부분에 대한 원고의 청구가 다시 이유 없다고 판시하였다 하여도 이는 항소심의 심판대상이 아닌 부분에 대하여 한 불필요한 판단으로서 판결의 결과에는 아무런 영향이

없다(대법원 1995. 5. 26. 선고 94다1487 판결). 또한 원고 일부 승소의 제1심 판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고는 항소심이 변경판결을 한 경우에도 마찬가지로 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다(대법원 2002. 2. 5. 선고 2001다63131 판결).

나. 선택적 병합의 경우

(1) 심판의 순서와 판단 방법

선택적 병합은 당사자가 병합된 청구 중 어느 하나의 청구가 인용될 것을 해제조건으로 하여 다른 청구의 심판을 구하는 것이므로, 법원은 병합된 청구 중 이유 있는 청구 어느 하나를 골라서 원고 청구를 인용하면 되고 다른 청구에 대하여 심판할 필요가 없지만, 원고 패소의 경우에는 모든 청구를 심리하여야 한다. 따라서 원고승소 판결에서는 이유 있는 청구 하나만을 선택·판단하여 인용하면 되지만, 원고패소 판결에서는 병합된 청구 전부에 대한 판단을 거쳐 모두 기각하여야 한다. 청구를 인용하는 경우에 어느 청구를 인용하느냐는 법원의 선택에 맡겨져 있다.

선택적 병합은 실질적으로 한 개에 불과한 분쟁을 일거에 해결하기 위하여 상호 관련관계에 있는 여러 개의 청구가 하나의 소송절차에 불가분적으로 결합되어 있기 때문에 원칙적으로 전부판결을 하여야 하며, 선택적 청구 중 하나만을 기각하는 일부판결은 선택적 병합의 성질에 반하는 것으로서 법률상 허용되지 않는다(대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결). 선택적 병합 청구 중 하나의 청구를 인용하는 판결은 전부판결이지 일부판결이 아니다.

(2) 선택적 병합 청구의 하나에 대하여 일부만 인용되는 경우

선택적으로 병합된 청구의 청구취지가 가분적이고 그중 일부만 인용되는 경우에는 법원이 어떻게 선택·판단할 것인가 문제 된다. 예컨대 원고가 채무불이행과 불법행위를 선택적 청구원인으로 하여 동일한 청구취지의 손해배상을 구하였는데, 심리한 결과 불법행위 책임은 인정되나 원고에게도 20%

의 과실상계 사유가 있는 한편 채무불이행 책임은 모두 인정되거나 또는 인용 금액을 달리하여 일부 인정되는 경우에, 법원이 어떻게 선택·판단하여야 할 것인가? 선택적 병합의 경우에는 여러 개의 청구가 하나의 소송절차에 불가분적으로 결합되어 있기 때문에, 선택적 청구 중 하나에 대하여 일부만 인용하고 다른 선택적 청구에 대하여 아무런 판단을 하지 아니한 것은 위법하고, 법원은 선택적 청구 중 하나의 청구를 일부 인용하는 경우 다른 청구에 대하여도 판단하여 위 일부 인용액을 넘는 액수가 인용될 수 있는지 여부를 심리·판단할 필요가 있다(대법원 2016. 5. 19. 선고 2009다66549 전원합의체 판결).

(3) 선택적 병합 청구에 관한 판결에 대하여 항소한 경우 항소심의 심판 범위

제1심법원이 선택적 병합 청구에 대하여 원고패소 판결을 하면서 병합된 청구 중 어느 하나를 판단하지 않은 경우, 재판의 누락(민소 212조)으로 보아 제1심법원이 재판하여야 할 것인지 아니면 판단누락(451조 1항 9호)으로 보아 원고의 항소를 기다려 항소심에서 판단할 것인지 문제 된다. 판례는 이를 판단누락으로 보아, 제1심법원이 원고의 선택적 청구 중 하나만을 판단하여 기각하고 나머지 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지 아니한 조치는 위법한 것이고, 원고가 이와 같이 위법한 제1심판결에 대하여 항소한 이상 원고의 선택적 청구 전부가 항소심으로 이심된다고 한다(대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결).

나아가 선택적으로 병합된 청구 중 하나만을 인용한 원고승소 판결에 대하여 피고가 불복하여 항소한 경우에는 판단하지 아니한 나머지 청구까지도 항소심으로 이심되어 항소심의 심판대상이 되므로, 항소심은 제1심에서 인용된 청구를 먼저 심리하여 판단할 필요는 없고 선택적으로 병합된 여러 개의 청구 중 제1심에서 심판되지 아니한 청구를 임의로 선택하여 심판할 수 있으며, 원고의 청구를 모두 기각할 경우에는 원고의 선택적 청구 전부에 대하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2009다12580 판결). 이때 항

소심의 심리결과 다른 청구가 인정되고 그 결론이 제1심판결의 주문과 동일한 경우에도 피고의 항소를 기각하여서는 안 되며 제1심판결을 취소한 다음 새로이 청구를 인용하는 주문을 선고하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2006다7587 판결, 대법원 2024. 5. 30. 선고 2024다223321 판결). 이러한 법리는 원고의 청구를 인용한 판결에 대하여 피고가 항소를 제기하여 항소심에 이심된 후 원고가 다른 청구를 추가하여 선택적으로 병합된 경우에도 마찬가지이다(대법원 1993. 10. 26. 선고 93다6669 판결). 그리고 병합의 형태가 선택적 병합인지 예비적 병합인지는 당사자의 의사가 아닌 병합청구의 성질을 기준으로 판단하여야 하고, 항소심에서의 심판 범위도 그러한 병합청구의 성질을 기준으로 결정하여야 하므로, 실질적으로 선택적 병합 관계에 있는 두 청구에 관하여 당사자가 주위적·예비적으로 순위를 붙여 청구하였고, 그에 대하여 제1심법원이 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구만을 인용하는 판결을 선고하여 피고만이 항소를 제기한 경우에도, 항소심으로서는 두 청구 모두를 심판의 대상으로 삼아 판단하여야 한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다96868 판결).

마지막으로 선택적으로 병합된 수 개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우에 상고심법원이 선택적 청구 중 어느 하나의 청구에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다(대법원 2018. 6. 15. 선고 2016다229478 판결).

다. 예비적 병합의 경우

(1) 심판 순서 및 방법과 일부판결의 가부

예비적 병합의 경우에는 원고가 붙인 순위에 따라 심판하여야 하며(병합된 청구 중에 반드시 먼저 주위적 청구에 관하여 판결하여야 하는 점이 선택적 병합의 경우와 다르다), 주위적 청구를 인용할 때에는 다음 순위인 예비적 청구에 대하여 심판할 필요가 없으나, 주위적 청구를 배척(각하 또는 기각)할 때에는 예

비적 청구에 대하여 심판하여야 한다. 예비적 청구를 인용하는 경우에는 주문에 반드시 주위적 청구를 각하 또는 기각한다는 취지와 함께 예비적 청구를 인용하는 내용을 표시하여야 한다(대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1942 판결).

또한 예비적 병합의 경우에는 여러 개의 청구가 하나의 소송절차에 불가분적으로 결합되어 있기 때문에 주위적 청구를 먼저 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용하거나 주위적 청구만을 배척하고 예비적 청구에 대하여 판단하지 않는 등의 일부판결은 예비적 병합의 성질에 반하는 것으로서 법률상 허용되지 아니한다(대법원 2021. 5. 7. 선고 2020다292411 판결). 나아가 예비적 청구만을 분리하여 심리할 수 없으며, 피고로서도 예비적 청구에 관하여만 인낙을 할 수도 없고, 가사 인낙을 한 취지가 조서에 기재되었다 하더라도 그 인낙의 효력이 발생하지 아니한다(대법원 1995. 7. 25. 선고 94다62017 판결).

(2) 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 경우

제1심법원이 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대하여 판단하지 아니하는 판결을 한 경우, 재판의 누락(민소 212조)으로 볼 것인지 아니면 판단누락(451조 1항 9호)으로 볼 것인지 앞의 선택적 병합에서 본 바와 같은 문제가 발생한다. 판례는 이에 대하여 그러한 판결에 대한 상소가 제기되면 판단이 누락된 예비적 청구 부분도 상소심으로 이심이 되는 것이지, 그 부분이 재판의 누락에 해당하여 원심에 계속 중이라고 볼 것은 아니라고 하여(대법원 2000. 11. 16. 선고 98다22253 전원합의체 판결), 선택적 병합에서와 마찬가지로 보고 있다.

이러한 경우에 판단이 누락된 예비적 청구 부분은 상소로써 다투어야지, 이를 별소로 청구하는 것은 더 간편한 분쟁해결수단인 상소절차 이용권을 스스로 포기한 것으로서 권리보호의 이익이 없어 부적법하다. 또한 당사자가 상고하여 그 예비적 청구에 대한 판단누락 사유를 지적하였음에도 상고심에서도 그 쟁점에 관한 판단을 빠뜨림으로써 그 오류가 시정되지 않은 채

판결이 확정되었다면 재심사유(민소 451조 1항 9호)가 된다(대법원 2002. 9. 4. 선고 98다17145 판결).

(3) 예비적 병합 청구에 관한 판결에 대하여 항소한 경우 항소심의 심판 범위

예비적 병합 청구 중 주위적 청구를 인용하는 판결은 전부판결로서 이러한 판결에 대하여 피고가 항소하면 제1심에서 심판을 받지 않은 다음 순위의 예비적 청구도 모두 이심되고 항소심이 제1심에서 인용되었던 주위적 청구를 배척할 때에는 다음 순위의 예비적 청구에 관하여 심판을 하여야 한다.

예비적 병합 청구에 관하여 제1심에서 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구를 인용하였는데 피고만이 항소한 경우에는, 항소제기에 의한 이심의 효력은 당연히 사건 전체에 미쳐 불복하지 않은 주위적 청구에 관한 부분도 항소심에 이심된다(대법원 1995. 2. 10. 선고 94다31624 판결). 따라서 이러한 경우 피고가 항소심의 변론에서 원고의 주위적 청구를 인낙하여 그 인낙이 조서에 기재되면 그 조서는 확정판결과 동일한 효력이 있고, 그 인낙으로 인하여 주위적 청구의 인용을 해제조건으로 병합심판을 구한 예비적 청구에 관하여는 심판할 필요가 없어 사건이 그대로 종결된다(대법원 1992. 6. 9. 선고 92다12032 판결).

그렇지만 위와 같이 주위적 청구를 기각하고 예비적 청구를 인용한 제1심 판결에 대하여 피고만이 항소한 경우, 항소심의 심판범위는 피고가 불복신청한 예비적 청구에 한정될 뿐 원고의 부대항소가 없는 이상 주위적 청구는 이심은 되었더라도 심판대상이 될 수는 없고, 그 항소심판결에 대한 상고심의 심판대상도 역시 예비적 청구 부분에 한정된다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002므852 판결). 따라서 항소심에서 심리한 결과 오히려 주위적 청구가 이유 있고 예비적 청구가 이유 없는 경우라도, 원고의 부대항소가 없는 이상 제1심판결의 주위적 청구 기각 부분은 확정되고 항소심은 원판결을 취소하여 예비적 청구를 기각하여야 한다(대법원 1969. 8. 19. 선고 69누50 판결).

원고의 주위적 청구 중 일부를 인용하고 예비적 청구를 모두 기각한 제1

심판결에 대하여 피고가 불복 항소하자, 항소심이 피고의 항소를 받아들여 제1심판결을 취소하고 그에 해당하는 원고의 주위적 청구를 기각하는 경우에는, 항소심은 기각하는 주위적 청구 부분과 관련된 예비적 청구를 심판대상으로 삼아 이에 대하여도 판단하여야 한다(대법원 2000. 11. 16. 선고 98다 22253 전원합의체 판결).

제18장

소송중의 소

-
- 제1절 총 설 130
 - 제2절 중간확인의 소 135
 - 제3절 반 소 140
 - 제4절 청구의 변경 153

제1절 총 설

1. 서 설

앞서 본 바와 같은 ‘독립의 소’, 즉 다른 소송절차와 관계없이 그 제기에 의하여 새로운 판결절차를 개시시키는 소와 달리, ‘소송중의 소’라 불리는 소의 유형이 있다. 이는 이미 계속 중인 소송절차를 이용하여 그 당사자나 제3자가 이와 병합심리를 구하려 제기하는 소이다.

여기에는 ① 당사자가 제기하는 것으로서 청구의 변경(민소 262조), 중간 확인의 소(264조), 반소(269조), 승계인수(82조), 필수적 공동소송인의 추가(68조), 예비적·선택적 공동소송인의 추가(70조, 68조)가 있고, ② 제3자가 제기하는 것으로서 독립당사자참가(79조), 공동소송참가(83조), 승계참가(81조) 등이 있다.

그 밖에 소송중의 소의 특이한 형태로서 형사사건 계속 중에 피해자가 그 절차에 부대하여 배상신청을 하는 제도가 있다(소촉 26조).

소송중의 소는 이미 계속 중인 소송절차를 이용하는 것이기 때문에 유형별로 특별한 소제기방식과 병합요건 등이 정해져 있다. 위 유형 중 제3자가 제기하는 소송중의 소, 즉 소송참가와 당사자의 변경을 수반하는 승계인수, 필수적 공동소송인의 추가, 예비적·선택적 공동소송인의 추가에 관하여는 앞의 제10장과 제11장에서 이미 설명하였으므로, 본장에서는 당사자가 제기하는 소송중의 소에 관하여만 설명한다.

2. 소송중의 소로 인한 사물관할의 변동

가. 단독사건이 합의사건으로 변동된 경우

소송중의 소로 인하여 단독사건이 합의사건으로 변경되는 경우가 있는데, 사물관할과 관련하여 어떻게 처리할 것인가가 문제 된다. 이에 관하여는 민

사소송법과 ‘법관등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규’에 의하여 다음과 같이 처리하면 될 것이다.

(1) 먼저, 중간확인의 소나 반소의 제기 또는 청구의 변경으로 인하여 단독사건이 합의사건의 사물관할에 속하게 된 경우에는, 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 사건의 전부를 합의부에 이송하는 것이 원칙이다. 민사소송법은 반소에 관하여서만 명문의 규정(민소 269조 2항 본문)을 두고 있지만, 중간확인의 소가 제기되거나 소가 변경되어 단독사건이 합의사건의 사물관할에 속하게 된 경우에도 유추적용하여 마찬가지로 처리해야 할 것이다.

당사자가 이를 이유로 이송신청을 하는 경우 이는 민사소송법 34조 1항의 관할위반에 따른 이송을 촉구하는 취지에 불과한 것이므로, 그 이송신청서에는 인지를 붙이지 아니하고 문건으로 전산입력한 후 가철하여야 한다(인지액·편철방법예규). 단독판사의 이송결정에 대하여는 즉시항고가 가능하나(민소 39조), 이송신청을 기각하는 결정에 대하여는 항고가 허용되지 않는다. 이에 관하여는 제3장(관할) 참조.

다만 이러한 원칙에 대하여 아래에서 보는 바와 같이 사건을 이송하지 않고 계속하여 단독판사가 심리하도록 하는 예외가 매우 폭넓게 허용되어 있음을 유의하여야 한다.

(2) 추가된 반소에 관하여 상대방이 관할위반이라고 항변하지 아니하고 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술하여 원래의 단독판사에게 변론관할(민소 30조)이 생긴 경우에는 이송하지 아니하고 단독판사가 계속 심리하여야 한다(269조 2항 단서). 이는 중간확인의 소나 소의 추가적 변경의 경우에도 마찬가지로 유추적용하여야 할 것이다.

(3) 비록 위 (2)항에 의한 변론관할이 생기지 아니한 경우에도, 다음과 같은 경우에는 재정단독결정을 받아 계속하여 단독판사가 심리할 수 있다.

첫째로, 합의부의 구성원인 단독판사는 심리중인 단독사건이 소의 변경,

독립당사자참가 또는 반소의 제기 등으로 인하여 합의사건에 속하게 된 경우라도 그 사건이 재정단독 대상사건에 해당하는 때에는 소속 합의부의 재정단독결정을 받아 이를 계속 심판할 수 있다. 이 경우 합의부는 구성원이 기명날인한 재정단독결정을 기록에 첨부하여 소의 변경 등으로 인한 경우에는 사건을 담당하던 단독판사에게, 독립당사자참가 또는 반소 등의 제기로 인한 경우에는 사건배당 주관자에게 제출한다(사무분담·사건배당예규 13조 3항).

둘째로, 합의부에 소속되지 않은 단독판사는 단독으로 심리중인 사건이 소의 변경, 독립당사자참가 또는 반소의 제기 등으로 인하여 합의사건에 속하게 되었지만 재정단독 대상사건에 해당하는 때에는, 해당 사건에 대하여 기록회부서[전산양식 A1101]를 첨부하여 재정결정부에 기록을 회부한 후 재정단독결정을 받아 계속 심리할 수 있다(사무분담·사건배당예규 13조 4항).

위와 같이 단독사건이 소의 변경 등으로 합의부의 사물관할에 속하게 되었으나 재정단독결정으로 단독판사가 계속 심판하게 되었을 때에는 새로운 입력을 하지 아니하고 기존의 사건기록표지 및 사건번호를 계속 사용하며, 독립당사자참가 또는 반소의 제기 등이 있었으나 재정단독결정이 있는 경우에는 다음과 같이 처리한다(사무분담·사건배당예규 13조 7항, 8항).

① 종전의 독립당사자참가 또는 반소 등의 사건에 관하여 재정단독결정일자와 결과를 입력한 다음, 사건접수건수 및 처리건수의 산정에서는 이를 제외한다.

② 재정단독결정일자를 기준으로 하여 새로운 단독사건으로 접수·배당한다.

③ 사건기록 표지는 새로 작성하지 아니하고 재정단독결정전의 기록표지 중 사건번호를 한 줄로 그어 말소한 다음 그 여백에 새로운 사건번호를 기재하고 ‘담임’란 하단부분에 “재정단독”이라고 주서한다.

나. 합의사건이 단독사건으로 변경된 경우

위와 반대로 소의 교환적 변경 또는 청구취지의 감축으로 인하여 원래 합

의사건이던 것이 소송목적의 값이 5억 원 이하로 떨어져 단독사건으로 변경되었더라도 단독판사에게 이송할 필요가 없다. 소송목적의 값의 산정 및 사실관찰은 소제기 시를 표준으로 하는 것이 원칙이고 합의부는 언제든지 단독사건을 합의부에서 심판할 것으로 스스로 결정할 수 있으므로(법조 32조 1항 1호, 민소 34조 3항), 이러한 경우에 사건을 단독판사에게 이송하게 되면 소송경제에 반하게 될 뿐만 아니라 합의부에서 계속 심판하더라도 당사자에게 불리하지 않기 때문이다.

다. 소액사건에 소송중의 소가 제기되어 소액사건이 아니게 된 경우

(1) 소액사건이 소의 변경으로 소송목적의 값이 소액사건의 범위를 초과하게 되거나, 중간확인의 소 또는 반소의 제기 및 변론의 병합으로 인하여 소액사건에 해당하지 않는 사건과 병합 심리하게 된 경우에는, 본래의 소액사건은 소액사건심판 대상에서 제외된다(소액규 1조의2 단서).

다만 두 개 이상의 소액사건이 병합되어 심리됨으로 인하여 그 소송목적의 값의 합산액이 소액사건의 소송목적의 값을 초과하였다고 하더라도 소액사건임에는 변함이 없다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다43176 판결). 따라서 반소의 경우에도 본소와 합산하지 아니한 반소의 소송목적의 값만으로 소액사건이 아니게 된 때에 한하여 소액사건의 심판대상에서 제외되는 것이다.

(2) 먼저, 소액사건으로 심리 중에 반소, 중간확인의 소, 소의 변경 등으로 인하여 합의사건으로 변경된 경우에는 위 가의 (1)항에서 본 바와 같이 합의부로 이송하여야 할 것이다. 소액사건에는 통상의 심리절차와는 다른 여러 가지 절차상 특례가 마련되어 있으므로 변론관찰이 생길 수 없고, 재정단독결정을 받더라도 어차피 통상의 소송절차에 따라 진행하여야 하기 때문이다.

(3) 다음으로, 소액사건이 청구의 변경 등에 의하여 소액사건 아닌 민사단독사건으로 변경된 때에는 다음과 같이 처리한다.

만일 소액사건 전담법관을 두고 있지 않은 경우에는 소액사건이나 단독사

건이나 지방법원 단독판사의 사물관할에 속함에는 아무런 변동이 없으므로 원래의 단독판사가 계속하여 심리하면 된다. 다만 재판사무시스템의 소액사건 ‘종국요지’란에 그 사유를 기입하여 소액사건으로서는 종결처리한 다음, 이를 단독사건 신건으로 접수하여 새로 사건번호를 부여하되 ‘비고’란에 종전의 소액사건번호를 기재하여야 하며, 사건기록 표지도 새로 작성하여 붙여야 한다(전자소송의 경우 전자입력 및 사건기록이송 등으로 처리한다).

다음으로, 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 소액사건이 청구의 변경에 의하여 소액사건 아닌 민사단독사건으로 변경된 때에는 특별한 사유가 없는 한 재배당을 실시한다(사무분담·사건배당예규 26조 1항, 14조 6호). 소액사건 전담법관을 두고 있는 경우 착오에 의하여 소액사건이 민사단독사건으로 또는 민사단독사건이 소액사건으로 접수·배당된 때에도 같다(14조 7호).

이러한 경우 재배당이 완료된 경우에는 다음과 같이 사무를 처리한다(사무분담·사건배당예규 26조 4항).

- ① 사건배당부 ‘비고’란에 재배당의 취지를 기재한다.
- ② 종전 사건은 재배당의 취지를 입력하여 종결처리하고, 그 기록을 재배당된 담당 재판부로 송부하되, 기록 표지의 완결공람은 하지 않는다.
- ③ 위 ②항의 기록을 송부받은 재판부에서는 송부받은 날짜를 기준으로 이를 신건으로 접수하여 새로운 사건번호를 부여한 다음 기록표지를 새로 작성하고 ‘담임’란 하단부분에 “재배당”이라고 주서한다.

시·군법원은 소액사건 이외의 민사사건을 관할할 수 없으므로 관할법원(본원)으로 이송하여야 한다.

제2절 중간확인의 소

1. 총 설

‘중간확인의 소’란 소송계속 중에 그 청구의 판단에 대해 선결관계 있는 법률관계에 관하여 그 소송절차에 병합하여 제기하는 확인의 소이다(민소 264조). 원래 선결적 법률관계(예컨대 건물인도청구 소송에서 그 건물의 소유권의 존부)에 대하여는 종국판결의 이유에서만 판단될 뿐 주문에 표시되지 않기 때문에 기판력이 생기지 않는데, 그에 관하여 기판력 있는 판단을 얻기 위해서는 별소를 제기할 수도 있으나, 기존의 소송절차를 이용할 수 있도록 하는 것이 소송경제와 재판의 통일을 기하는方便이 된다고 하여 인정되는 제도이다.

중간확인의 소는 원고는 물론 피고도 제기할 수 있다. 원고가 제기하는 것은 소의 추가적 변경 내지 청구의 확장에 해당하고, 피고가 제기하는 것은 일종의 반소에 해당하는데, 다만 그 성질에 착안하여 민사소송법이 별도의 규정을 두고 있을 뿐이다.

중간확인의 소는 단순한 공격방어방법이 아니라 소송중에 제기되는 일종의 독립된 소이므로, 이에 대한 판단도 중간판결(민소 201조)의 형식이나 판결이유에만 기재할 것이 아니라 기판력이 발생하도록 반드시 종국판결의 주문에 기재하여야 한다.

2. 중간확인의 소의 요건

가. 본래 청구의 다툼 있는 선결적 법률관계에 대한 확인청구일 것

재판이 소송의 진행중에 쟁점이 된 법률관계의 성립 여부에 매인 때여야 한다(민소 264조 1항). 즉 중간확인의 소의 대상에 관한 판단이 본래의 청구에 관한 결론을 좌우할 수 있는 선결적 관계가 있어야 한다. 예를 들면 소유

권이전등기말소청구 소송에서 소유권의 존부나 이자청구 소송에 있어서 원본채권의 존부 등이 이에 속한다. 이러한 다툼 있는 선결적 법률관계는 본소 청구의 전부 또는 일부에 관하여 적어도 중간확인의 판결을 할 때까지 현실적으로 존재하여야 하나, 청구원인뿐 아니라 항변사실과 관련된 것도 포함된다(대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다215744 판결).

한편 중간확인의 소도 확인의 소에 관한 일반원칙에 따라 확인의 이익이 있어야 하지만, 소송상 선결적 법률관계에 관하여 사실상·법률상 다툼이 있으면 확인의 이익은 충족되며, 그 밖에 별도의 확인의 이익이 필요 없다.

나아가 현재의 법률관계에 관한 확인을 구하여야 하므로, 과거의 법률관계라든가 현재의 사실관계에 관한 확인을 구할 수 없음은 일반의 확인의 소에서와 같다. 또한 확인청구가 아닌 경계확정의 소와 같은 형성청구를 중간 확인의 소로 청구할 수도 없다.

나. 소송계속 이후 사실심 변론종결 이전에 제기할 것

소송계속 이전에 제기하거나 사실심 변론종결 이후에 제기하는 것은 허용되지 않는다. 소유권이전등기청구나 말소등기청구의 소송을 진행하다가 소유권의 존부에 관한 기판력을 얻기 위하여 소유권확인청구를 추가하는 소변경은 항소심에서도 유효하게 할 수 있다(대법원 1973. 9. 12. 선고 72다1436 판결). 항소심에서 제기하는 경우에도 상대방의 동의를 얻을 필요는 없다는 것이 통설이다.

다. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것

본래의 청구와 중간확인청구는 같은 종류의 소송절차에 의하여 심리할 수 있어야 하므로, 예컨대 가사소송사항이나 행정소송사항에 대하여는 중간확인 소가 불가능하다.

또한 중간확인청구 사건이 다른 법원의 전속관할에 속하지 않아야 한다

(민소 264조 1항 단서). 토지관할·사물관할은 문제 되지 않는다.

3. 사무처리

가. 소의 제기와 접수

(1) 중간확인의 소도 소의 일종이므로 그 제기절차에는 제16장에서 설명한 내용이 그대로 적용된다. 따라서 반드시 서면에 의하여야 하며(민소 264조 2항) 소장의 필수적 기재사항(249조)을 명기하여야 한다.

인지도 독립의 소와 동일한 기준에 의하여 붙여야 할 것이다. 다만 중간확인의 소에 의하지 아니하고 당초부터 본래의 청구에 병합하여 하나의 소로 제기하였더라면 본래의 청구와 중복청구(인지규 20조)에 해당하는 청구를 중간확인의 소로 제기하는 경우에는, 중간확인청구의 소송목적의 값이 본래 청구의 소송목적의 값보다 다액인 경우에 한하여 중간확인청구의 인지액에서 이미 납부한 인지액을 공제한 금액을 추가로 납부하여야 한다(인지 5조). 예컨대 본래의 소가 매매계약 취소를 원인으로 하는 소유권이전등기말소청구이고 중간확인의 소가 그 선결문제인 소유권확인청구인 경우에는 소유권확인청구의 인지액에서 소유권이전등기말소청구의 인지액을 공제한 인지액을 추가로 납부하여야 한다. 이와는 달리 이른바 과실(果實)·위약금 등의 부대청구가 본래의 소송이고 그 선결문제인 본 청구가 중간확인의 소로 제기되는 경우(예컨대 이자청구만을 하였다가 중간확인의 소로 원금채권의 존재확인을 구하는 경우)에는 그 본 청구에 관한 인지를 붙여야 할 것이다.

(2) 중간확인의 소장이 접수되면 민사사건으로 전산입력하고, 별도의 사건번호를 부여한 후 소장 기타 관계서류를 본래의 소송기록에 합철한다(인지액·편철방법예규). 이 경우 기록표지의 '사건번호'란에는 위 사건번호를 병기하고 괄호 안에 중간확인의 소임을 부기하며 '사건명'란에도 중간확인의 소의 사건명을 부기하여야 한다(예: 2025가합100(중간확인) 소유권확인). 당사자의 지위에 관한 표시도 "원고(중간확인원고) / 피고(중간확인피고)" 등으로 호

청을 부기하여야 하며, 피고가 중간확인의 소를 제기한 경우에는 “원고(중간확인피고) / 피고(중간확인원고)”로 기재하면 될 것이다.

(3) 접수된 중간확인의 소장에 대하여는 소장에 준하여 심사를 한 후 상대방에게 소장부분을 송달하여야 한다(민소 264조 3항, 민소규 64조 2항).

(4) 피고의 소송대리인이 중간확인의 소를 제기하려면 반소에 준하여 특별수권이 필요하나(민소 90조 2항 1호 참조), 원고의 소송대리인이 이를 제기하는 경우에는 소의 추가적 변경에 준하는 것이기 때문에 본소 청구의 대리권에 당연히 포함되고 특별수권이 필요 없다고 본다.

(5) 중간확인의 소의 제기로 인하여 사물관할이 달라진 경우에는 앞의 제1절 2.에서 설명한 대로 처리하면 된다.

나. 심 리

(1) 중간확인의 소에 대한 심리방법은 대체로 소의 추가적 변경 또는 반소의 경우에 준한다. 먼저, 앞서 본 중간확인의 소의 요건 구비 여부를 심리한 후 그 흠이 있으면 독립한 소로서 취급될 수 없는 한 소각하의 판결을 하여야 할 것이다. 그 소가 독립한 확인의 소로서 요건을 갖추고 있을 때에는 바로 각하할 것이 아니라 별도의 사건으로 다루어야 한다. 별도의 사건으로 처리하기로 한 때에는 앞서 가의 (2)항에 따라 본래의 소송기록에 합철했던 중간확인의 소장과 관계서류를 떼어내고 중복되는 부분은 재판장의 명을 받아 등본을 작성한 다음 새로운 표지를 붙여 별건의 기록으로 조제한 뒤 결재공람을 거치고(사건번호는 그대로 유지된다), 이후의 절차를 진행하면 된다. 이 경우 새로 조제된 기록에 종전기록의 등본이 포함되어 있을 경우에는 등본기록 맨 끝에 “재판장의 명에 의하여 (필요부분)등본함”이라는 인증문구와 작성 연월일을 명기하고 서명날인하는 외에, 등본기록 표지의 우측 상단에 “(필요부분)등본”이라고 주서하여야 한다(재일 80-3 1책의 기록에 관하여 수개의 절차에서 동시에 소송이 계속하게 되는 때의 처리요령). 한편 본래의 소송기록

표지에 전술 가의 (2)항에 따라 부기했던 부분에는 ‘별건심리’ 등의 형식으로 중간확인의 소 부분이 별도의 사건으로 심리된다는 표시를 다시 부기하는 것이 옳다(전자소송의 경우에는 사건내역에 전자 입력하거나 공용 부전지 등을 활용한다).

(2) 소제기 요건이 갖추어졌으면 병합심리를 하여 1개의 종국판결에 의하여 한꺼번에 선고하는 것이 원칙이다. 본래의 청구와 중간확인의 소는 단순 병합관계에 있지만 통상의 단순병합과는 달리 본래의 청구와 선결관계에 있어 일체로서 처리될 것을 예정하고 있으므로 반드시 병합심리한 다음 1개의 전부판결을 하여야 하고, 변론을 분리하거나 일부판결(민소 200조)을 하는 것은 부적절하다. 또한 중간확인의 소에 대한 중간확인판결은 중간판결이 아니라 종국판결임을 유의해야 한다.

(3) 만일 중간확인의 소를 제기한 후 본래의 소가 취하된 경우라든지 각하의 판결 또는 확인의 대상인 법률관계에 대하여 판단함이 없이 다른 이유로 청구기각의 판결을 하는 경우에는 중간확인의 소가 이미 선결적 관계에 서지 않게 되므로 부적법하게 되어 각하판결을 하여야 할 것이다.

다만 독립한 확인의 이익이 있다고 인정되는 때에는 독립의 확인소송으로 처리하여야 한다. 이때는 위 (1)항의 경우와 달리 새로운 기록조제의 필요가 없으며 기존의 기록을 그대로 이용하여 심리를 진행하면 된다.

(4) 반면 이미 본안판결이 있는 후 상소심에서 선결적 관계가 소멸된 경우(즉 상소심 계속 후 본래의 소가 취하되거나 각하된 경우)에는 중간확인의 소 부분이 독립적으로 상소심의 심판대상이 되며 각하판결을 해서는 안 된다.

(5) 항소심에서 중간확인의 소가 제기된 뒤 항소가 취하되거나 각하되는 때에는 중간확인의 소는 당연히 종료되고 위 (3)항의 경우처럼 각하판결을 할 필요도 없는데, 이는 제1심을 거치지 아니한 독립의 확인소송을 인정할 수 없기 때문이다. 한편 본래의 소의 취하 후에 피고가 하는 중간확인의 소 취하의 경우에는 원고의 동의를 요하지 않는다(민소 271조).

(6) 재심의 소송절차에서 중간확인의 소를 제기하는 것은 재심청구가 인용될 것을 전제로 하여 재심대상소송의 본안청구에 대하여 선결관계에 있는 법률관계의 존부의 확인을 구하는 것이므로, 재심사유가 인정되지 않아서 재심청구를 기각하는 경우에는 중간확인의 소의 심판대상인 선결적 법률관계의 존부에 관하여 나아가 심리할 필요가 없으나, 한편 중간확인의 소는 단순한 공격방어방법이 아니라 독립된 소이므로 이에 대한 판단은 판결의 이유에 기재할 것이 아니라 종국판결의 주문에 기재하여야 할 것이므로 재심사유가 인정되지 않아서 재심청구를 기각하는 경우에는 중간확인의 소를 각하하고 이를 판결 주문에 기재하여야 한다(대법원 2008. 11. 27. 선고 2007다 69834 판결).

제3절 반 소

1. 총 설

‘반소’란 소송계속 중에 피고가 그 소송절차를 이용하여 원고를 상대로 제기하는 소를 말한다(민소 269조). 반소는 관련성 있는 분쟁을 동일 소송절차를 이용하여 한꺼번에 해결하는 것이 별소에 의한 심판보다도 소송경제에 적합하고 또 재판의 모순·저촉도 피할 수 있게 되기 때문에 인정되고 있다.

가. 피고의 제기

반소는 피고가 제기하는 소송중의 소로서, 이에 의하여 청구의 추가적 병합의 형태가 이루어진다. 본소의 능동적 주체와 수동적 주체가 반소에서는 역으로 바뀌므로, 본소원고는 반소피고로, 본소피고는 반소원고로 불린다.

반소는 본소의 수동적 당사자인 피고가 제기하는 것이므로, 독립당사자참가나 승계참가의 경우에 참가인과의 관계에서 피고의 지위에 서는 종전의

원고·피고도 참가인을 상대로 반소를 제기할 수 있다(대법원 1969. 5. 13. 선고 68다656 판결). 그러나 본소의 당사자가 아닌 자 사이, 예를 들면 보조참가인을 상대로 하거나 보조참가인이 제기하는 반소는 부적법하다.

나. 독립의 소

반소는 항변 등의 방어방법이 아니라 피고가 자기의 신청에 대하여 판결을 구하는 독립한 소이므로, 본소 청구기각 신청 이상의 적극적 내용이 포함되어야 한다. 따라서 동일 채권에 대한 존재확인의 본소에 대하여 부존재확인을 구하는 반소라든가, 이행의 소에 대하여 채무부존재확인을 구하는 반소는 모두 그 청구의 내용이 실질적으로는 본소청구 기각을 구하는 것과 다를 바 없으므로 확인의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005다40709 판결). 그러나 원고의 소유권확인 본소청구에 대한 피고의 소유권확인의 반소청구나, 원고의 채무부존재확인의 본소청구에 대한 피고의 채무이행의 반소청구는 모두 본소청구 기각 이상의 적극적 내용이 포함된 반소로서 허용된다. 나아가 원고가 피고에 대하여 교통사고로 인한 손해배상채무의 부존재확인을 구할 이익이 있어 먼저 본소로 그 부존재확인을 청구한 뒤에 피고가 그 후에 그 손해배상채무의 이행을 구하는 반소를 제기한 경우에는, 일단 소송요건을 구비하여 적법하게 제기된 본소가 그 후에 상대방이 제기한 반소로 인하여 본소청구에 대한 확인의 이익이 소멸하여 소송요건에 흠이 생김으로써 다시 부적법하게 된다고 볼 수는 없다(대법원 1999. 6. 8. 선고 99다17401 판결). 민사소송법 271조는 본소가 취하된 때에는 피고는 원고의 동의 없이 반소를 취하할 수 있다고 규정하고 있고, 이에 따라 원고가 반소가 제기되었다는 이유로 본소를 취하한 경우 피고가 일방적으로 반소를 취하함으로써 원고가 당초 추구한 기판력을 취득할 수 없는 사태가 발생할 수 있는 점을 고려하면, 위 법리와 같이 반소가 제기되었다는 사정만으로 본소청구에 대한 확인의 이익이 소멸한다고는 볼 수 없다(대법원

2010. 7. 15. 선고 2010다2428 판결).

임대인이 본소로 차임지급을 청구하는 경우, 민법 628조에 의한 임차인의 차임감액청구권은 사법(私法)상의 형성권이지 법원에 대한 형성판결을 구할 권리가 아니므로, 임차인은 이를 독립한 방어방법으로만 주장하면 되지 독립한 반소로써 제기할 수 없다(대법원 1968. 11. 19. 선고 68다1882 판결)(다만 반소로 제기된 경우 석명권을 행사하여 당사자로 하여금 이행의 소나 확인의 소로 변경하도록 유도하는 것이 바람직하다).

반소는 방어방법이 아니라 소의 변경과 같이 본안신청을 이루는 것으로서 종국판결의 주문과 청구취지에서 그 내용이 밝혀져야 하므로, 공격방어방법에 관한 민사소송법 147조, 149조, 285조의 실권제재 규정이 적용되지 아니하여 단순히 시기에 늦게 제출하였다는 이유로는 각하할 수 없다. 다만 소의 변경과 마찬가지로 반소의 제기도 소송절차를 현저하게 지연시키지 아니할 것을 그 요건으로 한다(민소 269조 1항 본문).

다. 예비적 반소

반소에는 전형적 형태인 단순 반소 외에 예비적 반소(조건부 반소)가 있다. 이는 본소청구가 인용되거나 기각될 것에 대비하여 조건부로 제기하는 반소이다. 예컨대 원고의 임대차 종료를 원인으로 한 토지인도 청구의 본소에 대하여 토지의 임차권이 존속한다는 피고의 주장이 받아들여지지 아니하고 임대차가 종료한 것으로 인정되는 경우에 대비하여, 피고가 예비적 반소로서 공작물 매수를 청구하는 것이 가능하다. 실무상 본소청구가 인용될 것을 정지조건으로 심판을 구하는 예비적 반소가 많은데, 이러한 형태의 예비적 반소에서 본소청구가 기각되는 경우에는 반소청구에 대하여 아무런 판단이 필요 없으며(대법원 1991. 6. 25. 선고 91다1615 판결), 본소청구가 각하되거나 취하되면 반소청구도 본소와 운명을 같이 하여 소멸된다. 또한 본소청구 기각판결이 확정되면 해제조건의 성취로 인하여 예비적 반소의 계속은 소급적

으로 소멸한다(대법원 2018. 4. 6. 자 2017마6406 결정. 이 경우 소송비용에 산입되는 변호사보수의 기준이 되는 소송목적의 값은 예비적 반소를 고려함이 없이 본소만을 기준으로 산정하여야 한다).

1심에서 본소청구를 인용하면서 위와 같은 형태의 예비적 반소에 대하여도 판단하였는데, 피고가 불복하여 항소심에서 본소청구를 기각하는 경우에는 반소에 대한 제1심판결도 취소하는 판결을 하여야 한다. 한편 본소청구가 인용될 것을 조건으로 심판을 구하는 예비적 반소가 제기된 경우 1심이 본소청구를 배척하면서 예비적 반소에 대해서도 배척하는 판단을 하였다면 예비적 반소에 대한 판단은 심판대상이 될 수 없는 소에 대한 것이어서 그 효력이 없다고 할 것이므로, 피고가 반소에 대해 항소하지 않았더라도 원고가 본소에 대해 항소하고 만일 항소심이 원고의 본소청구를 인용하는 때는 피고의 예비적 반소도 심판대상으로 삼아 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2006다19061 판결).

가지급물반환 신청은 소송중의 소의 일종으로서 그 성질은 본안판결의 취소·변경을 조건(반대로 본안 판결이 변경되지 아니하는 것을 해제조건으로 한다고 볼 수도 있다)으로 하는 예비적 반소라 할 것이므로(이를 부진정 예비적 반소로 구분하는 견해도 있다), 본안에 관한 항소심판결 중 원고 패소 부분을 파기하면 항소심의 가집행의 원상회복신청에 대한 재판 중 원고 패소 부분도 당연히 파기를 면할 수 없고(대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다40668 판결), 가집행의 선고가 붙은 1심판결에 대하여 피고가 항소를 하였지만 피고의 항소가 기각될 경우 항소심은 따로 가지급물반환 신청에 대한 판단을 하지 않는다(대법원 2005. 1. 13. 선고 2004다19647 판결).

한편 점유권을 기초로 한 본소에 대하여 본권자가 본소청구의 인용에 대비하여 본권에 기초한 장래이행의 소로서 예비적 반소를 제기하고 양 청구가 모두 이유 있는 경우, 법원은 점유권에 기초한 본소와 본권에 기초한 예비적 반소를 모두 인용해야 하고 점유권에 기초한 본소를 본권에 관한 이유

로 배척할 수 없다. 이러한 법리는 점유를 침탈당한 자가 점유권에 기한 점유회수의 소를 제기하고, 본권자가 그 점유회수의 소가 인용될 것에 대비하여 본권에 기초한 장래이행의 소로서 별소를 제기한 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2021. 3. 25. 선고 2019다208441 판결). 나아가 위와 같이 본소, 반소를 모두 인용한 판결이 확정되면, 점유자가 본소 확정판결에 의하여 집행문을 부여받아 강제집행으로 물건의 점유를 회복할 수 있다. 본권자의 소유권에 기한 반소청구는 본소의 의무 실현을 정지조건으로 하므로, 본권자는 위 본소 집행 후 집행문을 부여받아 비로소 반소 확정판결에 따른 강제집행으로 물건의 점유를 회복할 수 있다. 이러한 과정은 애당초 본권자가 허용되지 않는 자력구제로 점유를 회복한 데 따른 것으로 그 과정에서 본권자가 점유 침탈 중 설치한 장애물 등이 제거될 수 있다. 다만 점유자의 점유회수의 집행이 무의미한 점유상태의 변경을 반복하는 것에 불과할 뿐 아무런 실익이 없거나 본권자로 하여금 점유회수의 집행을 수인하도록 하는 것이 명백히 정의에 반하여 사회생활상 용인할 수 없다고 인정되는 경우 또는 점유자가 점유권에 기한 본소 승소 확정판결을 장기간 강제집행하지 않음으로써 본권자의 예비적 반소 승소 확정판결까지 조건불성취로 강제집행에 나아갈 수 없게 되는 등 특별한 사정이 있다면 본권자는 점유자가 제기하여 승소한 본소 확정판결에 대한 청구이의의 소를 통해서 점유권에 기한 강제집행을 저지할 수 있다(대법원 2021. 2. 4. 선고 2019다202795 판결).

2. 반소의 요건

가. 상호 관련성

(1) 상호 관련성의 의미와 심사

반소청구는 본소의 청구나 방어방법과 서로 관련이 있어야 한다(민소 269조 1항 단서). 이 요건은 소 변경에서 청구의 기초의 동일성에 대응하는 요건으로서, 서로 관련성이 있어야 변론과 증거조사를 함께 실시함으로써 심리

의 중복과 재판의 저축을 피할 수 있기 때문이다. 따라서 상호 관련성의 유무 및 내용은 이를 요건으로 삼은 취지를 감안하여 사안마다 구체적으로 판단할 문제이다.

상호 관련성 요건은 다른 반소 요건과 달리 직권조사사항이라 할 수 없고, 원고가 동의하거나 이의 없이 응소한 경우에는 상호 관련성이 없어도 반소는 적법한 것으로 보아야 할 것이므로(사익적 요건) 이의권 상실의 대상이 된다(대법원 1968. 11. 26. 선고 68다1886 판결).

(2) 본소의 청구와 상호 관련성

이는 본소와 반소의 양 청구가 소송물 또는 그 대상·발생원인에서 법률상 또는 사실상으로 공통성이 있다는 것을 뜻한다.

구체적으로는 양자의 청구취지가 동일한 법률관계의 형성을 목적으로 하는 경우, 예컨대 쌍방의 이혼청구라든가, 양자의 청구원인이 동일하거나 또는 대상·발생원인 등에서 주된 부분이 공통되는 경우, 예컨대 원고가 토지 소유권의 확인을 청구한 데 대하여 피고가 반소로 그 부동산에 대한 임차권의 확인을 구하거나(대상의 공통), 원고가 어떤 교통사고에 기한 손해배상청구를 한 데 대하여 피고도 원고에 대하여 그 교통사고로 인한 손해의 배상을 반소로 청구하는(발생원인의 공통) 경우를 말한다.

(3) 본소의 방어방법과 상호 관련성

이는 반소청구가 본소의 항변사유와 대상·발생원인에서 법률상 또는 사실상으로 공통성이 있다는 것을 뜻한다. 예컨대 피고가 상계의 항변을 제출하고 반소로 그 자동채권의 잔액의 지급을 청구한다든가, 원고의 물건반환 청구에 대하여 피고가 유치권을 주장하면서 그 피담보채권의 지급을 청구하는 경우이다. 또한 먼저 제기된 소송에서 상계 항변을 제출한 다음 그 소송 계속 중에 자동채권과 동일한 채권에 기한 소송을 반소로 제기하는 것도 가능하다(대법원 2022. 2. 17. 선고 2021다275741 판결).

본소의 방어방법과 상호 관련된 반소는 그 방어방법이 반소 제기 당시에

현실적으로 제출되어야 하며 또 법률상 허용되어야 한다. 따라서 상계금지 채권(민법 496조 내지 498조, 715조)을 청구원인으로 한 본소에 대한 상계항변처럼 법률상 허용되지 않는 항변에 바탕을 둔 반소나, 소송절차상 실기한 방어방법으로 각하된 항변에 바탕을 둔 반소는 부적법하다.

나. 본소 절차를 현저히 지연시키지 않을 것

원래 반소는 원고의 청구 변경에 대응하는 제도이고, 더구나 시기에 늦게 반소를 제기함으로써 본소의 소송지연책으로 악용되고 있는 현실(특히 건물 인도 청구사건에서 그러하다)을 고려하여 민사소송법은 반소의 제기도 청구 변경의 경우와 같이 소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것을 그 요건으로 정하고 있다. 본소에 지장을 줄 정도로 반소권을 남용하여서는 곤란하기 때문이다.

따라서 반소청구의 상호 관련성이 인정된다 하더라도 반소청구의 심리를 위하여 본소절차가 지연되게 되어 별소에 의하는 것이 오히려 적절한 경우에는 반소를 허용하지 않을 수 있다.

위 요건은 상호 관련성과는 달리 피고의 이익을 위한 사익적 요건이 아니고 소송촉진을 위한 공익적 요건으로서 직권조사사항이므로, 이익권 포기나 상실의 대상이 될 수 없다.

다. 본소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

(1) 본소의 변론종결 전일 것

본소의 계속 이전에 반소를 제기하거나 변론종결 이후에 반소를 제기할 수는 없다. 변론을 종결할 때까지란 사실심 변론종결을 말하므로, 법률심인 상고심에 제기된 반소는 부적법하다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2003다70010 판결).

그러나 본소의 소송계속은 반소 제기의 요건일 뿐 그 존속요건은 아니므

로, 반소 제기 후에 본소가 각하·취하되어 소멸되어도 예비적 반소가 아닌 한 반소에는 영향이 없다. 그러나 본소가 취하되면 피고는 원고의 응소 후라도 그의 동의 없이 반소를 취하할 수 있다(민소 271조).

(2) 항소심에서의 반소 제기의 요건

항소심에서의 반소 제기는 상대방의 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우이거나 또는 상대방의 동의를 받은 경우에만 가능하며, 상대방이 이의를 제기하지 아니하고 반소의 본안에 관하여 변론을 한 때에는 반소 제기에 동의한 것으로 본다(민소 412조).

심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우란, 반소청구의 기초를 이루는 실질적인 쟁점이 제1심에서 본소의 청구원인 또는 방어방법과 관련하여 충분히 심리되어 상대방에게 제1심에서의 심급의 이익을 잃게 할 염려가 없는 경우를 말한다(대법원 2005. 11. 24. 선고 2005다20064 판결). 그 예로는 중간확인의 반소, 본소와 청구원인을 같이 하는 반소, 제1심에서 이미 충분히 심리한 쟁점과 관련된 반소(대법원 1996. 3. 26. 선고 95다45545 판결, 대법원 1997. 10. 10. 선고 97다7264 판결), 제1심에서 제기한 반소의 내용을 항소심에서 확장하거나 제1심에서 제기한 반소를 주위적 청구로 하고 항소심에서 이에 대하여 예비적으로 반소청구를 추가하는 경우(대법원 1969. 3. 25. 선고 68다1094 판결) 등을 들 수 있다. 다만 제1심에서는 반소를 제기하지 않았던 피고가 항소심에서 원고의 청구가 인용될 경우에 대비하여 제기한 예비적 반소는 원고의 심급의 이익을 해할 우려가 없다고 할 수 없다(대법원 1994. 5. 10. 선고 93므1051 판결).

상대방의 동의 간주와 관련하여 반소청구의 기각 답변만으로는 이의 없이 반소의 본안에 관하여 변론을 한 때에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 1991. 3. 27. 선고 91다1783 판결).

형식적으로 확정된 제1심판결에 대한 피고의 항소추완신청이 적법하여 해당 사건이 항소심에 계속된 경우 그 항소심은 다른 일반적인 항소심과 다

를 바 없으므로, 원고와 피고는 형식적으로 확정된 제1심판결에도 불구하고 실기한 공격·방어방법에 해당하지 아니하는 한 자유로이 공격 또는 방어방법을 행사할 수 있고, 나아가 피고는 상대방의 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우 또는 상대방의 동의를 받은 경우에는 반소를 제기할 수도 있다(대법원 2013. 1. 10. 선고 2010다75044 판결).

라. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것

반소청구는 본소청구와 동일한 절차에 의하여 심리할 수 있는 한 토지판할·사물관할을 따지지 아니하고 본소가 계속되어 있는 법원에 제기할 수 있음이 원칙이다. 다만 반소사건이 다른 법원의 전속관할에 속하지 않아야 한다.

3. 사무처리

가. 반소의 제기와 접수

반소는 본소에 관한 규정을 따른다(민소 270조)는 명문규정이 있을 뿐 아니라 성질상으로도 반소는 독립된 소의 일종이므로 그 제기의 절차에는 제16장에 설명한 내용이 그대로 적용된다. 따라서 반드시 서면(반소장)에 의하여야 하며(소액사건에서는 구술제소 등 예외가 허용됨) 소장의 필수적 기재사항이 명시되어야 한다. 당사자의 호칭은 ‘반소원고, 반소피고’로 관례화되어 있고, 본소에서의 원고·피고의 표시 뒤 괄호 안에 그 지위를 덧붙여 “원고(반소피고) / 피고(반소원고)”의 식으로 표시한다.

반소장에도 소장과 동일한 기준에 의한 인지를 붙여야 한다(인지 4조 1항). 예외적으로 본소와 ‘목적이 동일한 소송물’인 때에는 인지를 붙일 필요가 없다(2항). 여기서 ‘목적이 동일한 소송물’이란 강학상 의미의 소송물(청구원인에 의하여 특정되는 실체법상의 권리 또는 법률관계)이 같은 경우(예: 채무부존재 확인의 본소와 채무이행청구의 반소)뿐만 아니라 다툼의 대상이 된 물건이 같은 경우(예: 동일 건물에 대한 인도의 본소와 임차권확인인 반소)까지 포함하는

넓은 의미라고 설명된다. 다만 일부 청구의 본소에 대하여 전부에 관한 반소가 제기된 경우와 같이 양소의 목적이 일부만 중첩되는 때에는 그 나머지 부분에 대해서는 반소장에 인지를 붙여야 한다(차액주의).

반소장이 접수되면 별도의 사건번호를 부여함과 동시에 통상의 소의 예에 준하여 사건명까지도 붙여서 민사사건으로 전산입력하고 기록에 합철하며(인지액·편철방법예규) 기록표지에도 기재하여야 한다. 만약 반소장에 반소의 명칭이 기재되지 않은 경우에는 청구취지와 청구원인 등을 참작하여 적절히 사건명을 만들어야 하며, 그것이 어려울 때에는 재판부에 문의하여 지시를 받아야 한다.

기록의 표지 중 ‘사건번호’란에는 반소의 사건번호를 병기하고 괄호 안에 본소 및 반소의 표시를 부기하여야 하고, ‘사건명’란에도 반소의 사건명을 병기하여야 하며(예: “2025가합90(본소) 토지인도 / 2025가합100(반소) 소유권확인”), 당사자의 지위 표시에 있어서도 “원고(반소피고) / 피고(반소원고)”와 같이 그 호칭을 부기하여야 한다. 그리고 반소와 관련하여 제출되는 서류는 본소의 기록에 가철한다.

반소장에 대하여는 소장에 준하여 심사를 하고 상대방(원고)에게 반소장 부분을 송달하여야 한다(민소 255조 1항, 민소규 64조 2항).

소송대리인의 반소 제기에는 특별수권이 필요하므로 특별수권의 유무를 조사할 필요가 있다. 변호사인 소송대리인에 대한 위임장 양식에는 위의 특별수권 문구가 인쇄되어 있으므로 별 문제가 없으나, 비변호사 소송대리인의 반소장 접수에서는 주의를 요한다. 이와 관련하여 성년후견인이 소송행위에 대하여 후견감독인의 동의를 받은 경우 특별한 사정이 없는 한 민사소송법 56조 2항이 정하는 소송행위를 제외하고는 일체의 소송행위를 할 수 있다고 봄이 타당하고, 이러한 취지는 가정법원이 민법 938조 2항에 따라 법정대리권의 범위 중 소송행위에 관하여 법원의 허가를 받도록 정한 경우에도 마찬가지이다. 따라서 성년후견인이 가정법원으로부터 본소에 관해 일

체의 소송행위 및 이를 위한 변호사 선임행위에 관한 허가를 받았다면 반소에 관한 소송행위와 상고 제기가 민사소송법 56조 2항이 정한 특별수권사건에 해당하지 않으므로 그와 같은 소송행위를 할 수 있다(대법원 2023. 3. 30. 선고 2022재다300253 판결).

나. 반소 제기로 인한 사물관할의 변동과 이송

단독판사 사건인 본소 청구의 심리 중에 합의부 사건인 반소가 제기된 때에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 사건 전부를 합의부로 이송하여야 하며, 다만 변론관할(민소 30조)이 생긴 후에는 이송할 필요가 없다(269조 2항). 주의할 것은 반소의 제기로 인하여 합의사건에 해당되는지 여부는 반소 자체의 소송목적의 값만을 기준으로 할 것이지, 본소와 반소의 소송목적의 값을 합산한 값을 기준으로 하여서는 안 된다는 점이다.

그 밖에 반소의 제기로 인하여 사물관할의 변동이 생긴 경우의 이송신청, 이송기각결정에 대한 즉시항고, 그 밖의 처리 절차에 관하여는 제1절의 2.에서 설명하였다.

다. 심 리

(1) 반소사건의 심리에서는 먼저 반소요건과 일반 소송요건의 존부를 심리하고 위 각 요건이 구비되었다고 인정되면 본안의 심리를 진행한다. 일반 소송요건을 갖추지 못한 반소는 물론 이를 각하하여야 하나, 일반 소송요건은 갖추었지만 반소의 요건만을 갖추지 못한 경우(예: 상호 관련성의 흠, 청구의 병합요건의 흠, 항소심에서의 반소에 대한 원고의 부동의 등) 어떻게 처리할 것인가가 문제 된다.

반소의 요건 중 본소와의 상호 관련성은 사익적 요청에 기한 것으로서 이의권의 대상이 될 뿐이나, 그 밖에 본소의 사실심 계속과 변론종결 전일 것, 본소와 동종의 절차에 의할 것, 다른 법원의 전속관할에 속하지 아니할 것

등과 함께 소송절차를 현저히 지연시키지 아니할 것이라는 요건은 모두 공익적 요청에 기한 것이므로, 이에 위반한 반소는 부적법 각하하여야 한다는 견해와, 독립된 소로서의 요건을 갖추고 있을 때에는 본소와 분리하여 심판하여야 한다는 견해가 나뉘어 있다. 판례는 항소심에서 상대방의 동의 없이 제기한 반소를 각하한 원심의 조치가 위법하지 않다고 판시한 바 있다(대법원 1965. 12. 7. 선고 65다2034 판결).

(2) 반소가 적법하면 병합심리를 하여 1개의 전부판결로써 판결하는 것이 원칙이다. 다만 병합심리로 인하여 오히려 소송이 번잡하게 되거나 지연이 초래된다고 인정될 때에는 분리심리를 하여 따로 본소와 반소에 대하여 각각 일부판결을 할 수도 있다(민소 200조 2항).

일부판결을 하기 위하여 반소에 관한 변론을 분리한 경우에는 기록까지 분리하여 별책으로 조제하여야 할 것이다. 그 구체적 방법에 관하여는 제2절 3. 나.에서 한 중간확인 소의 분리에 관한 설명 참조.

본소와 반소를 분리하여 판결한 때에는 일부판결이 되지만, 동시에 1개의 판결을 한 때에는 1개의 전부판결이다. 따라서 어느 일방에 대한 상소는 상소불가분의 원칙에 따라 그 전부에 대하여 확정차단과 이심의 효력이 생긴다. 비록 1개의 전부판결을 하더라도 본소와 반소에 대하여 각각 판결주문을 내야 하되, 다만 소송비용의 재판은 특별한 사정이 없는 한 본소로 인한 비용과 반소로 인한 비용을 구분하지 아니하고 총비용에 관한 부담을 정하는 것이 통례이다. 그러나 본소와 반소를 모두 기각하는 경우에는 본소비용과 반소비용을 구분하여 부담을 정한다.

라. 반소의 취하

반소의 취하에서도 원칙적으로 원고의 동의가 필요함은 물론이다. 다만 본소가 취하된 때에는 원고의 동의를 얻을 필요 없이 반소를 취하할 수 있지만(민소 271조), 본소가 원고의 의사와 관계없이 부적법하여 각하된 경우

에는 원고의 동의가 있어야 반소를 취하할 수 있다(대법원 1984. 7. 10. 선고 84다카298 판결). 반소를 취하한 반소원고가 소취하 후 재소금지의 효과를 받게 되는 것은 보통의 소취하의 경우와 같다(267조 2항).

마. 본소가 취하된 후의 반소

본소가 취하되었더라도 반소의 소송계속에는 영향이 없으므로(대법원 1970. 9. 22. 선고 69다446 판결) 반소만에 대하여 심판하여야 한다. 이 경우에는 기록을 분책할 필요 없이 종전 기록을 그대로 유지 이용하되, 본소 취하 이후의 조서 작성이나 판결서 작성에서 당사자의 호칭은 원고·피고의 표시를 없애고 반소원고·반소피고로 통일함은 물론이고, 기재 순서도 반소원고·반소피고의 순으로 바뀌어야 한다. 본소가 취하되어 반소가 독립한 소로 되었다는 이유로 반소원고를 원고로, 반소피고를 피고로 약칭하게 된다면 종전의 본소에 관한 원고, 피고와 혼동될 염려가 있으므로 피하여야 한다. 서증의 부호(갑, 을호증)도 혼동의 염려와 번거로움을 피하기 위해 바꾸지 않고 그대로 쓰는 것이 좋을 것이다.

다만 본소의 인용이나 기각을 조건으로 하는 예비적 반소의 경우에는 본소가 취하되면 반소도 조건의 불성취로 인하여 소멸한다고 볼 것이다.

바. 항소가 취하 또는 각하된 경우

먼저, 항소심에서 적법하게 반소가 제기된 후 항소가 취하됨으로써 본소가 확정되어 종료된 경우, 반소를 어떻게 처리할 것인가가 문제 된다. 이에 대하여는 다음 세 가지 견해가 있을 수 있다.

① 본소에 대한 항소심 심판을 전제로 제1심을 생략한 채 제기된 반소는 그에 대한 심리와 판결을 할 필요 없이 본소의 소송계속 소멸과 함께 당연히 소멸한다는 견해, ② 반소는 독립된 소이므로 이에 대한 상대방의 심급의 이익을 보장하기 위하여 제1심법원으로 이송하여 심리하도록 하여야 한다는

견해 그리고 ③ 항소심에서는 상대방의 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우 또는 상대방이 동의를 받은 경우에 한하여 반소를 제기할 수 있고(민소 412조 1항), 일단 적법하게 제기된 반소는 독립된 소로서의 실질을 가지고 있어 그 소송계속에는 영향이 없으므로, 제1심법원으로 이송할 필요 없이 반소만에 대하여 항소심에서 계속 심판하여야 한다는 견해가 그것이다.

다음으로, 항소가 부적법 각하되면 본소의 항소심 소송계속 자체가 부적법하게 되므로, 본소의 적법한 항소심 소송계속을 전제로 제1심을 생략한 채 제기된 반소도 당연히 소멸하며, 이 경우에는 반소에 대하여 판결을 할 필요 없이 소송절차가 종료된다 보아야 할 것이다(대법원 2003. 6. 13. 선고 2003다16962 판결).

제4절 청구의 변경

1. 총 설

가. 청구의 변경의 의의

‘청구의 변경’ 또는 ‘소의 변경’이란 법원과 당사자의 동일성을 유지하면서 청구를 변경하는 것을 말한다(민소 262조). 다시 말하면 소송물의 변경으로서, 이는 그 변경의 대상에 따라 청구취지의 변경과 청구원인의 변경으로 나누어 볼 수 있고, 변경의 모습에 따라 교환적 변경과 추가적 변경(이는 이른바 청구의 후발적 병합에 해당하며 단순병합·선택적 병합 또는 예비적 병합의 어느 한 형태로 행하여진다)으로 나누어 볼 수도 있다.

실무에서는 토지인도, 건물철거, 부동산의 점유로 인한 부당이득, 혹은 인신사고로 인한 손해배상 등 소송에서 측량감정·시가감정 혹은 신체감정 등 감정 결과에 따라 소장에 기재된 청구의 내용을 변경하는 경우가 자주 발생한다.

나. 청구의 변경의 대상

(1) 청구취지의 변경

청구취지의 변경은 원칙적으로 ‘청구의 변경’이 된다. 즉 청구원인을 그대로 둔 채 소의 종류를 다르게 바꾸거나(예컨대 동일한 부동산에 대한 소유자임을 원인으로 하여 인도청구를 하다가 소유권확인청구로 바꾸는 것) 또는 심판의 대상이나 내용을 바꾸는(예컨대 A 건물 인도청구를 B 건물 인도청구로 변경) 것은 모두 청구의 변경이 된다.

한편 청구취지가 변경되는 경우 중에는 심판의 범위를 변경하는 ‘청구의 확장’과 ‘청구의 감축’이 있다. 먼저, ‘청구의 확장’에는 예컨대 선이행조건 부청구나 상환이행청구를 단순히 이행 청구로 바꾸는 등 질적 확장과 금전채권 중 일부만을 청구하다가 나머지 부분까지 전부 청구하는 것으로 바꾸는 등 양적 확장이 있는데, 어느 것이나 청구의 추가적 변경에 해당한다. 반면 단순히 이행 청구를 상환이행 청구로 바꾸는 질적 감축이나 금전 청구를 양적으로 일부 줄이는 양적 감축 등 ‘청구의 감축’은 감축된 한도만큼 소의 일부 취하를 뜻할 뿐(대법원 1993. 9. 14. 선고 93누9460 판결) 본래 의미의 청구의 변경에는 해당하지 않는다.

(2) 청구원인의 변경

청구취지를 그대로 둔 채 청구원인에 기재한 사실관계를 전혀 다른 사실관계로 바꾸어 주장하는 경우, 예컨대 매매대금청구에서 대여금청구로 바뀌어 주장하는 경우 청구의 변경이 된다.

또한 하나의 사실관계에서 같은 목적을 가진 여러 개의 청구권이 발생하는 경우에 청구취지를 그대로 둔 채 그 근거가 되는 청구권을 바꾸는 것, 예컨대 손해배상청구 소송에서 처음에는 불법행위를 원인으로 주장하다가 뒤에 그 원인을 계약불이행으로 바꾸는 것이나 또는 소유권이전등기청구 소송에서 그 등기원인을 바꾸는 것(대법원 1992. 3. 27. 선고 91다40696 판결: 매매를 양도담보약정으로 바꾼 경우, 대법원 1997. 4. 11. 선고 96다50520 판결: 매

매를 취득시효 완성으로 바꾼 경우)은 판례가 취하고 있는 구소송물론을 따르면 모두 청구의 변경이 있는 것으로 된다.

반면 원인무효를 이유로 하는 말소등기청구사건의 소송물은 당해 등기의 말소등기청구권이고 그 청구원인, 즉 말소등기청구권의 발생원인은 당해 '등기원인의 무효'라 할 것이며 등기원인의 무효를 뒷받침하는 개개의 사유는 독립된 공격방어방법에 불과하여 별개의 청구원인을 구성하는 것이 아니다(대법원 1993. 6. 29. 선고 93다11050 판결).

(3) 청구취지 및 청구원인의 변경

청구취지와 함께 청구원인을 변경하는 경우는 항상 청구의 변경이 된다.

다. 청구의 변경의 모습

(1) 추가적 변경

구청구를 유지하면서 신청구를 추가함으로써 청구를 확장하는 형태이다. 따라서 청구의 후발적 병합에 해당하므로 청구의 병합요건(민소 253조)을 갖 추어야 한다. 청구의 추가적 변경은 단순병합·선택적 병합·예비적 병합의 세 가지 유형으로 행하여지므로, 추가적 변경이 있는 경우에는 앞의 제17장에서 설명한 위 각각의 병합의 형태에 따라 처리 및 심리를 하면 된다.

(2) 교환적 변경

청구의 교환적 변경은 건물 인도청구를 건물에 대한 소유권확인청구로 바꾸거나, 목적물의 인도 청구를 목적물 멸실에 따른 전보배상 청구로 바꾸는 경우와 같이 구청구를 갈음하여 신청구를 제기하는 변경 형태이다. 종래의 청구취지나 청구원인의 철회를 전제로 하며, 구청구의 취하와 신청구의 추가가 결합된 형태라는 것이 판례 및 통설이다. 다만 종전 청구를 취하한다는 명백한 표시가 없는 한 신청구가 부적법한 경우에는 교환적 변경이라 볼 수 없다(대법원 1975. 5. 13. 선고 73다1449 판결).

청구의 교환적 변경을 신청한 경우, 판례는 변경 전후의 청구의 기초 사

실의 동일성에 영향이 없으므로 구청구의 취하에 피고의 동의가 없어도 취하의 효력이 발생하는 것으로 보고 있다(대법원 1962. 1. 31. 선고 4294민상 310 판결). 그렇지만 학설은 피고가 이미 본안에 관하여 응소한 이후라면 피고의 동의를 얻어야 구청구의 취하의 효력이 생기며(민소 266조 2항), 만일 피고의 동의를 얻지 못하면 소의 변경은 구청구에 신청구를 추가한 형태의 추가적 변경으로 된다는 것이 다수설이다.

한편 청구의 교환적 변경이 있는 경우 구청구는 취하된 것으로 보게 되므로 신청구에 관한 소멸시효중단의 효력이나 제척기간 준수의 효과는 특별한 사정이 없는 한 신청구가 제기된 청구의 변경 시점을 기준으로 발생하게 된다(대법원 2012. 3. 22. 선고 2010다28840 전원합의체 판결). 다만 판례는, 원고가 채권자대위권에 기해 청구를 하다가 당해 피대위채권 자체를 양수하여 양수금청구로 소를 변경한 경우도 청구원인의 교환적 변경으로서 채권자대위권에 기한 구청구는 취하된 것으로 보아야 하지만 그 채권자대위소송의 소송물과 양수금청구의 소송물이 모두 같은 채권으로서 동일한 점, 시효중단의 효력은 특정승계인에게도 미치는 점 등에 비추어 당초의 채권자대위소송으로 인한 시효중단의 효력이 소멸하지 않는다고 보고 있다(대법원 2010. 6. 24. 선고 2010다17284 판결).

(3) 변경형태가 불분명한 경우

청구의 변경이 교환적 변경인가 추가적 변경인가는 당사자의 의사해석에 의하여 정하여야 하는데, 당사자가 종전 청구를 취하한다는 명백한 표시 없이 새로운 청구로 변경하는 등으로 변경의 형태가 불분명한 경우에는 법원 으로서는 그 변경의 의사가 교환적인가 추가적인가 또 후자 중에서도 예비적인가 선택적인가의 점에 대하여 석명할 의무가 있으므로(대법원 2003. 1. 10. 선고 2002다41435 판결) 이를 석명하지 않은 채 교환적 변경이라고 단정 함은 위법하다(대법원 1995. 5. 12. 선고 94다6802 판결).

라. 청구의 변경과 구별해야 할 개념

(1) 공격방법의 변경

원고가 동일한 청구를 유지하면서 그 청구를 이유 있게 하는 공격방법을 바꾸는 것은 청구의 변경이 아니다. 이러한 공격방법의 변경에는 청구의 변경에서와 같은 제약이 없다. 예컨대 가등기에 기한 본등기청구에서 그 등기원인을 매매예약 완결이라고 주장하면서 위 가등기의 피담보채권을 처음에는 대여금채권이라고 주장하였다가 나중에는 손해배상채권이라고 변경하는 경우 위 가등기로 담보되는 채권이 무엇인지는 공격방어방법에 불과하다(대법원 1992. 6. 12. 선고 92다11848 판결).

한편 판례는, 소유권이전등기청구의 경우와는 달리, 원인무효를 이유로 하는 등기말소청구의 경우에는 말소등기청구권의 발생원인은 당해 '등기원인의 무효'에 국한되므로 사기에 의한 매매의 취소 주장과 매매의 부존재 또는 불성립의 주장은 다 같이 청구원인인 등기원인의 무효를 뒷받침하는 독립된 공격방어방법에 불과하다고 한다(대법원 1999. 9. 17. 선고 97다54024 판결). 또한 채권자가 사해행위의 취소를 청구하면서 그 보전하고자 하는 채권을 추가하거나 교환하는 것도 그 사해행위취소권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐이지 소송물 또는 청구 자체를 변경하는 것이 아니므로 소의 변경이라 할 수 없다(대법원 2003. 5. 27. 선고 2001다13532 판결).

(2) 청구취지의 정정·보충

청구의 변경과 구별해야 할 또 다른 것으로는 소장 기재의 오기나 누락을 정정하거나 보충하는 것이 있다. 이때에는 아래에서 설명하는 소의 변경의 법리와 사무처리방식이 적용되지 않을 경우가 있다. 예컨대 단순히 청구취지에 기재되어 있는 건물의 구조·평수·지번 등을 변경하거나 청구취지를 청구원인대로 재정리하는 것은 소의 변경이 아니므로, 청구의 변경의 요건을 갖추지 아니하여도 자유롭게 정정할 수 있다.

2. 요 건

가. 청구의 기초가 바뀌지 아니할 것

(1) 청구의 변경은 청구의 기초가 바뀌지 아니하는 한도 안에서만 할 수 있다(민소 262조 1항 본문).

청구의 기초의 의미에 관하여는 이익설, 사실설 및 병용설로 갈라져 있으나 어느 설에 의하든 실무처리에는 큰 차이가 없다. 동일한 생활 사실 또는 동일한 경제적 이익에 관한 분쟁에서 해결 방법에 차이가 있음에 불과한 청구취지 및 청구원인의 변경은 청구의 기초에 변경이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다28338 판결). 판례를 중심으로 청구의 기초에 동일성이 있다고 한 경우를 유형화해 보면 다음 네 가지를 들 수 있다.

① 동일한 청구원인을 기초로 청구의 취지를 변경한 경우: 보험회사가 교통사고 피해자 1인에게 손해를 변제하고 피보험자의 공동불법행위자를 상대로 구상금청구를 한 다음 항소심에 이르러 다른 피해자에게도 손해를 배상하고 구상금청구를 위해 청구취지를 확장한 경우와 같이 동일한 청구원인을 기초로 하여 청구취지를 양적으로 확장한 경우(대법원 1992. 10. 23. 선고 92다29962 판결)나 토지인도의 청구에 추가하여 그 토지상의 가건물철거를 구한 경우(대법원 1969. 12. 23. 선고 69다1867 판결)

② 신·구청구 중 어느 쪽이 다른 쪽의 변형물이거나 부수물인 경우: 소유권이전등기를 청구하다가 그 이전등기의무가 이행불능임을 전제로 손해배상청구로 바꾼 경우(대법원 1969. 7. 22. 선고 69다413 판결), 점포인도청구를 하다가 점포의 임료에 상당한 손해배상청구를 추가한 경우(대법원 1964. 5. 26. 선고 63다973 판결)

③ 동일한 급부나 형성을 목적으로 하면서 법률적 구성만을 달리하는 경우: 불법경작을 원인으로 손해배상을 청구하였다가 법률상 원인 없이 경작하였음을 원인으로 부당이득반환청구로 변경한 경우(대법원 1965. 4. 6. 선고 65다139 판결), 동일한 부동산을 증여받았음을 원인으로 소유권이전등기를

청구하다가 예비적으로 상속을 원인으로 상속지분의 확인을 구하는 것으로 변경한 경우(대법원 1992. 2. 25. 선고 91다34103 판결)

④ 동일한 사실이나 이익에 관한 것인데 분쟁 해결방법만을 달리하는 경우: 전부금의 지급을 청구하다가 경합되는 압류 및 전부명령 채권자에게 피전부채권을 무단변제하여 손해를 입었음을 이유로 그 배상을 청구하는 것으로 변경하는 경우(대법원 1988. 8. 23. 선고 87다카546 판결), 동일 부동산에 관한 원인무효로 인한 말소등기청구에서 명의신탁해지로 인한 이전등기청구 또는 말소등기청구로 변경한 경우(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결, 대법원 2001. 3. 13. 선고 99다11328 판결)

(2) 청구의 기초의 동일성 요건에 관하여서는 사익적 요건이라는 설과 공익적 요건이라는 설이 대립하나, 통설과 판례는 위 요건이 피고의 보호를 위해서 요구된다고 할 것이므로 이를 갖추지 못하더라도 피고가 소의 변경에 동의하거나 이의 없이 응소한 때에는 이의권을 상실하여 소의 변경을 불허할 수 없다고 한다(대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다6248 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2009다33655 판결).

나. 소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것

소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 차라리 별소에 의하도록 하는 것이 낫다는 취지에서 민사소송법 262조 1항 단서가 정하고 있는 요건이다. 새로 변경된 청구의 심리를 위해 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에는 절차지연에 해당하지 아니하지만(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결), 2회에 걸쳐 상고심으로부터 환송된 후 항소심 변론종결 당시에 청구를 변경하려는 것은 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에 해당한다(대법원 1964. 12. 29. 선고 64다1025 판결).

이 요건은 앞에서 본 청구의 기초의 동일성과 달리 공익적 요건에 해당하기 때문에 피고의 이의가 없어도 직권으로 조사하여야 한다.

다. 소송계속 이후 변론종결 이전에 신청할 것

(1) 변론종결 이전의 의미

청구의 변경은 변론을 종결할 때까지 할 수 있으며, 변론 없이 하는 판결의 경우에는 판결을 선고할 때까지 할 수 있다(민소 262조 1항). 변론을 종결할 때까지란 사실심 변론종결을 말하므로, 상고심에서는 청구를 변경할 수 없다. 즉 상고심에서는 사실에 관한 주장을 전제로 하는 청구취지 및 청구원인의 정정이나 변경은 허용되지 아니한다(대법원 1997. 12. 12. 선고 97누12235 판결). 다만 상고심에서 상고이유서 제출기간이 지나기 전에 회생절차가 폐지됨에 따라 채권자취소소송을 수계한 부인소송의 재수계 및 그에 따른 청구취지 변경이 필요한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 대법원으로서도 부득이 수계를 허가한 뒤 청구취지 변경 및 그에 따른 심리를 위하여 원심판결을 파기하여 사건을 원심법원에 환송해야 한다(대법원 2022. 10. 27. 선고 2022다241998 판결. 한편 판례는 상고이유서 제출기간이 지난 단계에 이른 경우 소송절차를 수계하도록 할 필요가 없다고 보았다. 대법원 2021. 2. 4. 선고 2018다304380 판결 등).

소송계속 전, 즉 소장송달 전에는 원고는 자유롭게 청구의 원인과 취지를 수정·증감할 수 있으며, 이는 민사소송법 262조의 ‘청구의 변경’에 해당하지 않는다. 한편 변론종결 후에는 청구의 변경을 신청할 수 없으며 신청이 있더라도 법원에서 반드시 재개할 의무가 있는 것은 아니지만, 재개를 하면 위의 흠은 치유된다.

(2) 항소심에서의 청구의 변경

항소심에서도 청구의 변경은 허용된다. 항소심에서 교환적 변경이 있는 경우 구청구 취하의 효력이 발생할 때에 그 소송계속은 소멸하므로 항소심에서는 구청구에 대한 제1심판결을 취소할 필요 없이 신청구에 대하여만 제1심으로서 판결을 하게 된다(대법원 1989. 3. 28. 선고 87다카2372 판결, 대법원 2018. 5. 30. 선고 2017다21411 판결). 주의할 것은 본안에 대한 종국판결

이 있는 후 구청구를 신청구로 교환적 변경을 한 다음 다시 본래의 구청구로 교환적 변경을 한 경우에는 종국판결이 있는 후 소를 취하하였다가 동일한 소를 다시 제기한 경우에 해당하여 부적법하게 된다는 점이다(대법원 1987. 11. 10. 선고 87다카1405 판결). 다만 그 경우에도 민사소송법 267조 2항의 취지에 반하지 아니하고 소제기를 필요로 하는 정당한 사정이 있는 등 취하된 소와 권리보호이익이 동일하지 않은 경우에는 다시 소를 제기할 수 있다(대법원 2021. 4. 15. 선고 2016다271523 판결).

(3) 제1심에서 전부 승소한 원고가 항소심에서 청구를 확장할 수 있는지 여부

원고가 제1심판결에서 전부 승소한 경우에 청구의 변경만을 목적으로 항소하는 것은 원칙적으로 항소의 이익이 없다.

그러나 가분적 채권에 대한 이행청구의 소를 제기하면서 그것이 나머지 부분을 유보하고 일부만 청구하는 것이라는 취지를 명시하지 아니한 경우에 그 확정판결의 기판력은 나머지 부분에까지 미치는 것이어서 별도로써 나머지 부분에 관하여 다시 청구할 수 없게 되므로, 일부 청구에 관하여 전부 승소한 채권자가 나머지 부분에 관하여 청구를 확장하기 위한 항소는 예외적으로 허용된다(대법원 1997. 10. 24. 선고 96다12276 판결). 또한 제1심에서 원고가 전부 승소하여 피고만이 항소한 경우에도 원고는 부대항소 없이도 항소심에서 청구취지를 확장할 수 있고(대법원 1969. 10. 28. 선고 68다158 판결) 이 경우에는 원고가 그 확장 부분만큼 부대항소를 한 것으로 본다(대법원 1992. 12. 8. 선고 91다43015 판결).

나아가 판례는 불법행위로 인한 손해배상청구권에 관하여 손해3분설을 취하고 있으면서도, 원고가 재산상 손해(소극적 손해)에 대하여는 형식상 전부 승소하였으나 위자료에 대하여는 일부 패소하였고, 이에 대하여 원고가 그 패소 부분에 불복하는 형식으로 항소를 제기하여 사건 전부가 확정이 차단되고 소송물 전부가 항소심에 계속되게 된 경우에는, 항소심에서 위자료는 물론이고 재산상 손해(소극적 손해)에 관하여도 청구의 확장을 허용하는

것이 상당하다고 한다(대법원 1994. 6. 28. 선고 94다3063 판결).

참고로 비송적 성격을 갖는 소송비용액확정절차에서는 신청인의 신청취지를 초과하여 소송비용액확정결정을 할 수는 없으나 신청취지의 금액이 모두 인용된 경우라고 하더라도 신청인은 증액을 위하여 항고를 제기하면서 신청취지를 확장할 수 있다(대법원 2024. 10. 22. 자 2024마6671 결정).

라. 그 밖의 객관적 병합요건을 구비할 것

이에 관하여는 제17장(소의 객관적 병합) 제2절 참조.

3. 청구의 변경의 절차와 사무처리

가. 청구의 변경의 절차

(1) 청구의 변경은 소송중의 소이므로 소제기의 일반원칙(민소 248조)에 따라 서면에 의하는 것이 원칙이겠으나, 서면에 의하지 아니한 청구취지의 변경에 대하여 상대방이 지체 없이 이의하지 아니한 경우 이의권이 상실된다(대법원 1993. 3. 23. 선고 92다51204 판결).

그런데 민사소송법 262조 2항은 청구취지의 변경에 한해서만 서면에 의하도록 하는 규정을 두고 있으므로 그 반대해석으로 청구원인은 말로 변경할 수 있는지가 문제 되나, 판례는 말로 해도 무방하다고 판시한다(대법원 1961. 10. 19. 선고 4293민상531 판결). 그러나 내용이 복잡한 경우에는 서면에 의하도록 권유하는 것이 바람직할 것이다. 판례는 피고 불출석 상태에서 원고가 말로 청구원인을 변경한 다음 법원이 피고에게 이에 대한 방어 기회를 주지 않고 변론을 종결하는 것은 위법하다고 하였다(대법원 1989. 6. 13. 선고 88다카19231 판결).

(2) 소변경 신청서에는 소송목적의 값이 증액되지 않는 경우에는 인지는 불이지 아니하고 문건으로 전산입력한 후 가철하여야 한다(인지 10조 단서, 인지규 2조의2, 인지액·편철방법예규). 다만 청구의 확장이나 추가적 변경을

내용으로 하는 신청서에는 확장 이후의 총 소송목적의 값에 의한 인지액과 종전 인지액과의 차액에 해당하는 인지를 추가로 붙여야 한다(인지 5조). 이와 같이 인지액을 상호 비교하여 차액을 계산하여야지 소송목적의 값을 비교한 차액을 기준으로 인지액을 계산하면 안 된다. 만약 추가로 붙일 인지액이 1,000원에 미달할 때는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(2조 2항). 교환적 변경 신청에서(예: 매매에 의한 소유권이전등기청구를 이행불능에 따른 손해배상 청구로 변경하는 경우) 변경 후의 소송목적의 값이 종전보다 증가할 때에도 동일하게 처리하여야 할 것이다. 청구취지는 그대로 둔 채 말로써 청구원인만을 변경 신청한 경우에도 소송목적의 값이 증가되지 않으므로 인지를 당해 기일의 조서 여백에 붙일 필요는 없다.

(3) 주의할 것은 청구 감축의 경우이다. 청구의 감축은 원칙적으로 소의 일부 취하에 해당하므로 반드시 서면에 의할 필요가 없고 말로써 할 수도 있으며, 다만 통상의 소 취하의 경우와 마찬가지로 상대방의 동의가 있어야 하고, 이러한 동의 및 동의의 거절은 반드시 명시적으로 하여야 하는 것은 아니고 묵시적으로 하여도 무방하다(대법원 1993. 9. 14. 선고 93누9460 판결). 또한 서면으로 청구를 감축한 경우에는 설령 문서의 제목을 청구변경신청서로 붙였다 하더라도 인지를 붙이게 하여서는 안 된다.

나. 접수 및 심사

신청서가 접수되면 문건으로 전산입력하고(인지액·편철방법예규) 관계 서류를 소송기록에 가철(등록)한다. 또 별도의 사건번호를 부여하지 않으며 사건명이 바뀐 경우에도 기록표지의 기존 사건명을 정정하지 않고 완결에 이르기까지 종전의 사건명을 계속 사용한다(재판사무규 19조 3항 본문).

청구의 변경 신청은 소송중의 소의 일종이므로(다만 소의 일부 취하에 해당하는 것은 제외) 비록 명문규정이 없더라도 소장에 준하여 심사하여야 하고 필수적 기재사항의 흠이나 인지부족에 대한 재판장 등의 보정명령에 불응할

경우에는 신청서의 각하명령(말로 된 경우에는 신청각하명령)을 하여야 할 것이다.

청구변경신청서는 그에 대하여 소장에 준하여 심사를 마친 후 적법하다고 인정되면 즉시 이를 상대방에게 송달하여야 한다(민소규 64조 2항). 청구취지의 변경신청서의 송달에 관하여는 민사소송법 262조 3항에 명문의 규정이 있다. 소의 추가적 변경이 있는 경우 추가된 소의 소송계속의 효력은 그 서면을 상대방에게 송달하거나 변론기일에 이를 교부한 때에 생긴다(대법원 1992. 5. 22. 선고 91다41187 판결). 이 경우 시효중단이나 법률상 기간 준수의 효력은 소변경신청서의 부분을 송달한 때가 아닌 그 이전인 소변경신청서를 제출한 때 발생한다(민소 265조). 다만 사해행위취소소송에서 원상회복 청구를 구하였다가 가액배상 청구로 변경한 후 다시 원상회복 청구로 변경한 경우에는 하나의 매매계약으로서의 당해 사해행위의 취소를 구하는 소 제기의 효과는 그대로 유지되고 있다고 보아야 하므로, 최초 소 제기 시에 발생한 제척기간 준수의 효과에는 영향이 없다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다67806 판결).

4. 심 리

가. 청구 변경의 적법 여부의 심사와 조치

청구 변경의 적법 요건 중 ‘청구 기초의 동일성’에 관하여 상대방이 지체 없이 이의하지 아니하고 변경된 청구에 관한 본안의 변론을 한 때에는 상대방은 더 이상 그 청구 변경의 적법 여부에 대하여 다투지 못한다(대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다6248 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2009다33655 판결). 그러나 그 밖의 요건인 ‘소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것’, ‘소송 계속 이후 변론종결 이전에 신청할 것’은 직권조사사항이므로 상대방이 본안의 변론을 하였는지와 상관없이 법원은 이를 심사할 수 있다.

청구의 변경 신청이 적법하다고 인정할 때에는 바로 변경된 청구에 대해

여 심판하면 족하며, 허가한다는 명시적 재판을 요하지 않는다. 다만 당사자가 이를 다투면 종국판결 이유 중에서 실시해 주는 것이 통례이다. 적법한 청구의 변경으로 인정되면 신청구에 대하여 심판하여야 하며, 구청구의 소송자료는 당연히 신청구의 자료로 된다. 추가적 변경의 경우에는 구청구와 함께 신청구가 심판의 대상으로 추가되지만, 교환적 변경의 경우에는 구청구의 소송계속이 소멸되므로 신청구만이 심판의 대상이 된다.

만일 청구의 취지 또는 원인의 변경 신청이 변경요건을 갖추지 못하여 유효하지 아니하다고 인정할 때에는 법원은 상대방의 신청 또는 직권으로 청구의 변경을 허가하지 아니하는 결정을 하여야 한다(민소 263조). 위 결정은 꼭 판결 전에 따로 해야 하는 것은 아니며 종국판결 이유 중에서 판시하여도 무방하다. 위 소변경 불허결정은 중간적 재판이므로 이에 대하여는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소로써만 다룰 수 있다(대법원 1992. 9. 25. 선고 92누5096 판결). 항소심이 제1심의 소변경 불허결정이 부당하다고 인정하면 원결정을 명시적 또는 묵시적으로 취소하고 그 변경을 허용하여 신청구에 대하여 심리를 개시할 수 있다.

나. 항소심에서 청구의 변경이 있는 경우 심판 방법

(1) 항소심에서 청구가 추가적으로 변경된 경우

(가) 항소심에서 단순병합의 형태로 소의 추가적 변경이 이루어져 청구가 확장된 경우, 항소의 직접적 심판대상에 대하여는 항소기각 또는 원판결취소의 판단을 하여야 하나, 추가로 병합된 부분은 실질상 제1심으로 판단하여야 한다. 따라서 만일 제1심판결이 정당하고 항소심에서 확장한 부분이 이유 없다면, 제1심판결에 대한 항소를 기각함과 아울러 추가된 부분에 대하여는 청구를 기각하는 주문을 내야 한다(대법원 1966. 1. 31. 선고 65다 1545 판결). 반면 제1심판결이 정당하고 항소심 확장 부분도 전부 인용될 경우에는, 우선 피고의 항소를 기각하는 주문과 함께 확장 부분 청구를 인용하

는 뜻의 주문을 내야 한다(대법원 1972. 6. 27. 선고 72다546 판결). 한편 원고 승소의 제1심판결에 대한 피고의 항소가 이유 있고 확장된 부분도 이유 없을 때에는 제1심판결을 취소하고 원고의 제1심 청구 및 확장 부분 청구를 모두 기각하는 뜻의 주문을 내야 한다.

(나) 제1심에서 원고의 청구가 기각되어 원고가 항소한 다음 항소심에서 선택적 병합의 형태로 소의 추가적 변경이 행하여진 경우, 항소심이 추가된 선택적 병합청구에 관하여 아무런 판단도 하지 아니하는 것은 판단누락에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다8365 판결). 이 경우 법원은 병합된 여러 개의 청구 중 어느 하나의 청구를 선택하여 심리할 수 있고 제1심에서 기각된 청구를 먼저 심리할 필요는 없으며, 어느 한 개의 청구를 심리한 결과 그 청구가 이유 있다고 인정될 경우에는 원고의 청구를 기각한 제1심판결을 취소하고 이유 있다고 인정되는 청구를 인용하는 주문을 선고하여야 한다(대법원 1993. 10. 26. 선고 93다6669 판결, 대법원 2021. 7. 15. 선고 2018다298744 판결).

한편 수 개의 청구가 제1심에서 처음부터 선택적으로 병합되고 그중 어느 한 개의 청구에 대한 인용판결이 선고되어 피고가 항소를 제기한 경우는 물론, 원고의 청구를 인용한 판결에 대하여 피고가 항소를 제기하여 항소심에 이심된 후 청구가 선택적으로 병합된 경우에도 항소심은 제1심에서 인용된 청구를 먼저 심리하여 판단할 필요는 없고, 선택적으로 병합된 수 개의 청구 중 제1심에서 심판되지 아니한 청구를 임의로 선택하여 심판할 수 있다고 할 것이나, 심리한 결과 그 청구가 이유 있다고 인정되고 그 결론이 제1심판결의 주문과 동일한 경우에도 피고의 항소를 기각하여서는 안 되며 제1심판결을 취소한 다음 새로이 청구를 인용하는 주문을 선고하여야 한다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다7023 판결).

(다) 제1심에서 전부 패소한 원고가 항소 후 예비적 청구를 추가적으로 병합하여 항소심의 심리 결과 주위적 청구에 관한 제1심판결을 그대로 유지할

경우 주문에서 “원고의 항소를 기각한다.”라고 선고하여야 하고, 예비적 청구가 항소심에서 병합되었다는 이유만으로 제1심판결을 취소 또는 변경하여야 하는 것은 아니다(대법원 1997. 8. 22. 선고 97다13023 판결). 이 경우 추가된 예비적 청구 부분에 대하여는 항소심에서 실질상 제1심으로 심리하여 별도로 그에 대한 인용 또는 기각의 주문을 내야 한다.

반면 제1심에서 전부 승소한 원고가 항소심에서 예비적 청구를 추가적으로 병합한 경우에, 심리 결과 제1심에서 판단한 원고의 주위적 청구가 이유 없을 때에는 제1심판결을 취소하여 주위적 청구를 기각한 다음에, 예비적 청구 부분에 관하여 실질상 제1심으로서 판단을 하여야 한다.

(2) 항소심에서 청구가 교환적으로 변경된 경우

항소심에서 청구가 교환적으로 변경된 경우에 구청구는 취하되어 소송계속이 소멸하고 신청구의 당부만이 심판의 대상이 되는 것이므로, 항소심은 제1심판결의 존재를 전제로 하는 원판결 취소나 항소기각의 주문을 낼 여지가 없고(대법원 1980. 11. 11. 선고 80다1182 판결), 사실상 신청구를 제1심으로 심판하여 새로운 주문을 내야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2017다21411 판결).

따라서 제1심에서 전부 패소 판결을 받은 원고가 불복하여 항소심에서 청구를 교환적으로 변경하였는데 항소심에서 신청구에 대하여 역시 이유 없어 기각할 경우라 하더라도, 주문에서는 신청구에 대하여 “이 법원에서 교환적으로 변경된 원고의 청구를 기각한다.”는 표시를 하여야 하고, “항소를 기각한다.”는 표시를 하여서는 아니 되고(대법원 1997. 6. 10. 선고 96다25449 판결), 이 경우 판결 이유에서는 변경된 신청구에 대하여 판단하였음에도 주문과 이유에서 “원고의 항소를 기각한다.”고 기재하였다면, 그 주문과 이유를 “교환적으로 변경된 청구를 기각한다.”고 경정할 수 있다(대법원 1999. 10. 22. 선고 98다21953 판결). 항소심이 신청구를 인용하는 때에도, 역시 제1심 판결 중 원고 패소 부분을 취소한다거나 피고의 항소를 기각한다는 주문 표

시를 하여서는 아니 된다(대법원 2009. 2. 26. 선고 2007다83908 판결). 또한 항소심에서 교환적으로 변경된 신청구에 관하여 심리한 결과가 제1심판결의 인용 주문 내용과 동일하다고 하더라도, 항소기각의 주문을 내서는 아니 되고, “당심에서 교환적으로 변경된 청구에 따라, 피고는 …하라.”라고 새로운 인용 주문을 내야 한다.

나아가 원고 승소의 제1심판결에 대하여 피고가 항소한 후 항소심에서 소의 교환적 변경이 적법하게 이루어졌다면 제1심판결은 소취하로 실효되고, 제1심판결과 함께 가집행선고도 실효되며(대법원 1995. 4. 21. 선고 94다58490 판결), 그 뒤에 피고가 항소를 취하한다 하더라도 항소취하는 그 대상이 없어 아무런 효력을 발생할 수 없다(대법원 1995. 1. 24. 선고 93다25875 판결).

(3) 항소심에서 청구가 감축된 경우

항소심에서 청구가 감축되었는데 그 잔여 부분에 대한 항소가 이유 없을 때에는 주문에서 원칙적으로 항소를 기각하는 것만으로 족하다. 그러나 항소기각의 주문만 낼 경우 제1심판결이 항소심에서 그대로 유지된 것 같은 외관을 보여 집행의 범위가 불명확해지기 때문에, 주문에 청구의 일부가 감축된 사실을 명확히 하여 주는 것이 바람직하다. 실무상으로는 ‘항소기각’ 주문 다음에 “제1심판결은 당심에서의 청구 감축에 의하여 다음과 같이 변경되었다. 피고는 원고에게 ○○원을 지급하라.”라고 기재하는 방식이 가장 많이 사용되고 또 바람직스럽다(대법원 1992. 4. 14. 선고 91다45653 판결 참조).

다. 청구의 변경을 간과한 경우의 조치

제1심에서의 청구의 변경이 적법함에도 불구하고 구청구만 심판하고 신청구의 심판을 빠뜨린 경우 어떻게 처리할 것인가 문제 된다.

만일 그것이 교환적 변경이었다면, 제1심판결은 취하되어 소송계속이 소멸된 구청구에 대하여 심판한 것으로써 처분권주의(민소 203조)를 위반한 판

결이므로 항소심은 이를 취소·파기하고 구청구의 소송종료선언을 해야 하고, 아울러 소송이 계속된 신청구에 대하여는 아무런 판단이 없어 재판의 누락(212조 1항)에 해당하므로 제1심이 추가판결을 하여야 한다(대법원 2003.

1. 24. 선고 2002다56987 판결).

만일 간과된 것이 추가적 변경이었다면 그 병합의 모습에 따라 각각 다르다. 먼저, 추가적으로 변경된 단순병합 청구에 대한 판단을 간과한 경우에는 제1심이 구청구에 대하여서만 판단하고 추가된 신청구에 대하여서는 재판을 누락한 위법(민소 212조 1항)이 있는 셈이므로, 항소심에서는 구청구에 대한 판단의 당부만 심판할 수 있을 뿐이고 누락된 신청구에 대하여는 제1심법원이 추가판결을 하여야 한다. 다음으로, 제1심법원이 원고의 청구를 기각하면서 추가적으로 병합된 선택적 청구에 대한 판단을 간과한 경우에는 재판의 누락으로 볼 수는 없고, 원고의 항소에 의하여 선택적 청구 전부가 항소심으로 이심되어 항소심 심판의 대상이 된다(대법원 1998. 7. 24. 선고 96다 99 판결). 마지막으로 제1심법원이 원고의 청구를 기각하면서 추가적으로 병합된 예비적 청구에 대한 판단을 간과한 경우에도, 이는 재판의 누락이 아니라 판단누락(451조 1항 9호)에 해당하므로, 항소에 의하여 누락된 예비적 청구 부분이 항소심으로 이심되어 항소심 심판의 대상이 된다(대법원 2000. 11. 16. 선고 98다22253 전원합의체 판결).